

**ANÁLISIS CRÍTICO DE LA REGLAMENTACIÓN DE LA INSOLVENCIA DE LA
DE LA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE A LA LUZ DE LA
LEGISLACIÓN COLOMBIANA**



CARLOS TORRES ORTIZ

**UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE DERECHO
NEIVA
2018**

**ANÁLISIS CRÍTICO DE LA REGLAMENTACIÓN DE LA INSOLVENCIA DE LA
DE LA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE A LA LUZ DE LA
LEGISLACIÓN COLOMBIANA**

CARLOS TORRES ORTIZ

**Monografía de grado como requisito para optar al título de
ABOGADO**

**Asesor
Dr. HELBER MAURICIO SANDOVAL CUMBE**

**UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PROGRAMA DE DERECHO
NEIVA
2018**

Nota de aceptación

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Neiva, 10 de agosto de 2018

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN.....	9
1. ORIGEN FINALÍSTICO DE LA REGLAMENTACIÓN SOBRE INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE EN LA LEY 1564 DE 2012.....	14
1.1 REFERENTE NORMATIVO, ANTECEDENTES, Y LEGISLACIÓN	14
1.2 CONSIDERACIONES DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LA INSOLVENCIA	23
2. ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA LEY DE INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE Y SU RELACIÓN CON LA LEY 1116 DE 2006	39
2.1 CONCEPTO GENERAL SOBRE INSOLVENCIA	39
2.2 INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE EN EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO.....	40
2.2.1 Objeto.	43
2.2.2 Requisitos para acogerse al procedimiento de insolvencia.	43
2.2.3 Órgano competente para el procedimiento de negociación de deudas y convalidación de acuerdos de la persona natural no comerciante.....	43
2.2.4 Costo del proceso de negociación de deudas.....	44
2.2.5 Forma de realizar el trámite	44
2.2.6 Efectos de la aceptación de la solicitud de negociación de deudas	45
2.2.7 Duración del procedimiento de negociación de deudas.	46
2.2.8 ¿Qué se logra con el proceso de negociación de deudas?	46
2.2.9 ¿Qué ocurre si se incumple con el acuerdo de pago?	47
2.2.10 Acuerdos privados.	47

2.2.11 Liquidación patrimonial.	47
2.3 LEY 1116 DE 2006	47
2.3.1 ¿Qué es un régimen de insolvencia y para qué sirve?	47
2.3.2 ¿Quiénes se pueden acoger al régimen de insolvencia?	48
2.3.3 ¿Quiénes no se pueden acoger al régimen de insolvencia?	49
2.3.4 ¿Ante cuál autoridad se puede solicitar el inicio de un proceso de reorganización o de liquidación judicial?	49
2.3.5 ¿Qué requisitos debe cumplir el deudor para iniciar un proceso de reorganización?.....	50
2.3.6 Aspectos importantes relacionados con el acuerdo de reorganización.	50
2.3.7 ¿Cuáles son las causales de terminación del acuerdo de reorganización?..	50
2.3.8 Aspectos relacionados con el proceso de liquidación judicial.....	51
2.3.9 Terminación.	51
2.4 ANTECEDENTES DE PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA EN OTROS PAISES	52
2.4.1 España	52
2.4.2 Argentina.	53
2.4.3 Perú	54
2.4.5 Ecuador.	56
3. ALTERNATIVAS MÁS EFECTIVAS PARA LLENAR LOS VACÍOS EN LA APLICACIÓN DE LA INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE	58
3.1 ANÁLISIS COMPARATIVO	58
3.1.1 De las partes en los procesos de insolvencia, deudor y acreedor.	58
3.1.2 De las condiciones para acceder al proceso de insolvencia.....	61

3.1.3 Del acuerdo de pagos.....	62
3.1.4 De la liquidación.	64
4. CONCLUSIONES	79
RECOMENDACIONES.....	81
BIBLIOGRAFÍA.....	82

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Evolución de desembolsos de cartera	31
Figura 2. Tasa de crecimiento real anual de cartera bruta	31

ABSTRAC

The purpose of this monographic work is to study and compare the current legislation on insolvency in Colombia, both for companies and non-traded natural persons in pursuit of their social economic purpose. For the fulfillment of this purpose we will make a tour of history and the treatment that has been given to it in the various legal institutions. The final objective is to clarify, through a critical analysis, the various practical situations found in the normative application developed for this purpose; especially in what has to do with the liquidation of assets within the insolvency of the non-traded natural person.

Key words: Natural person, insolvency, payments cessations, debtor, lender, agreements, asset liquidation.

INTRODUCCIÓN

Desde que nació la propiedad privada, nacieron con ella las obligaciones, y los créditos como consecuencia para adquirirla; en un símil dinámico con la vida del ser humano que necesita surtirse de bienes, bien como compensación por su trabajo o bien como un compromiso a ser cumplido en el tiempo con sustento en sus utilidades, que si no se logra lo enfrenta a una urgencia que debe ser resuelta con sus acreedores, con el gobierno y por ende con la misma sociedad. De la misma manera como los virus cíclicos atacan a la humanidad, de igual forma las crisis cíclicas de la economía atacan las empresas y los hogares como resultado. Frente a tal circunstancia los gobiernos tratan de implementar mecanismos que sobrelleven estos hechos con el menor daño posible mediante normas que orientan y pongan límites al aprovechamiento que pueda hacerse de éstas mismas en la búsqueda de mantener el equilibrio económico con el mantenimiento de la operación comercial y el dinamismo del consumo familiar y personal.

Desde la fuente misma de nuestro código civil, que es el derecho romano, se vislumbraban las bases que se establecen en el derecho para regular las relaciones comerciales en donde se tenía en cuenta la eventualidad de la quiebra del negociante o el incumplimiento del pago de la persona, pasando por el código de comercio que también se nutre de sus fuentes, llegando hasta las leyes especiales de insolvencia en Colombia, tales como la 1116 de 2006 en general, la 1429 de 2010 que le modifica algunos artículos y la 1564 de 2012 que contiene el trámite de insolvencia de la persona natural no comerciante.

El desarrollo del tema a nivel de ensayo monográfico de la insolvencia en Colombia debe ser de gran interés para el mundo académico y especialmente para el mundo empresarial, debido a la importancia social y el impacto que ello genera en la economía de la sociedad, sea a mediana escala, como es el caso de los pequeños centros de producción, así como también de la economía doméstica en cuanto a las personas naturales no comerciantes que son el dinamizador de tales operaciones comerciales que dan origen primigenio a los grandes conglomerados económicos e industriales que orientan el rumbo del mundo.

Haciendo una retrospectiva del asunto se puede observar que en Colombia a mediados de los noventas la crisis económica se agudizó por algo más de una década, esta crisis financiera colombiana de los años 90 (1998-2001) fue la más profunda y costosa de todas las que tuvieron lugar durante el siglo pasado¹, imponiéndole el reto al gobierno nacional de proponer o promover políticas enfocadas a enfrentar no solo los altos índices de desempleo, sino también las consecuencias que de ello derivarían, tal como la cesación de pagos.

¹ Millan, K. (2014). *Crisis del sistema financiero colombiano en los años 90*. Presentaciones Prezi. Recuperado De <https://prezi.com/lfljwarseonn/crisis-del-sistema-financiero-colombiano-en-los-anos-90>

Si bien para la época existía regulación sobre cómo abordar una cesación de pagos, el legislador del año 2006 decidió crear una metodología normativa para manejar la temática de insolvencia empresarial; teniendo en cuenta que expiraba la urgencia de la ley 550 de 1990. Surge entonces la necesidad de regular la insolvencia de la persona natural no comerciante, creando un procedimiento especial que regule las eventuales situaciones en las cuales el sujeto afectado por la cesación de pagos no fuese una persona jurídica comerciante o una natural comerciante, ya reguladas en otras normas. Como se puede ver en estas primeras líneas, todo el sistema jurídico generado alrededor de la insolvencia se centra en los comerciantes y las empresas; olvidando la persona natural como consumidor básico del sistema económico al que se le debe hacer un diagnóstico adecuado y una propuesta de solución eficiente frente a las dificultades económicas que pueda presentar. El gobierno nacional presenta la iniciativa legislativa orientada a reglamentar la insolvencia de las personas naturales no comerciantes², es decir, de aquellas personas que en el giro ordinario de sus actividades no se ocupaban del desarrollo de operaciones que la ley considera como mercantiles y que, por ende, presumen el ejercicio del comercio³, por lo tanto, no se tenían como comerciantes.

No obstante que de Colombia se tiene una percepción a nivel mundial de un buen manejo de la economía y altos índices de recuperación empresarial, lo mismo que celeridad en la resolución de procesos de insolvencia, y a pesar de que los sistemas concursales por su propia naturaleza contienen todo un desarrollo de carácter procedimental, no siempre son tratados con el rigor requerido como ha sido el caso del nuevo régimen colombiano. Es tanto que la misma ley de insolvencia empresarial se encuentra en una etapa básica que aún comete muchos errores en su aplicación. Entonces qué podemos decir de la insolvencia de las personas.

Colombia comenzó con un régimen de quiebra heredado del sistema español que no cumplió su cometido, antes, por el contrario, llevó a los mismos acreedores a desestimular su apertura en razón a grandes vacíos en su aplicación y a que solo daba como resultado mayores dificultades que las originarias de la crisis. Luego mediante el decreto 2264 de 1969, posteriormente incorporado al código de comercio de 1971, el sistema se reorganizó. De una parte, se reprodujo el fallido régimen de la quiebra, y de otra se actualizó trayendo el sistema de los concordatos preventivos de la misma ubicándose a la vanguardia con el concordato preventivo obligatorio. Se estableció el trámite obligatorio para las empresas más representativas de la economía nacional dado su nivel de endeudamiento, y la pérdida de los empleos a su cargo, haciendo que no se adelantara ante los jueces ordinarios sino en la Superintendencia de Sociedades, entidad de carácter administrativo.

² Ley 1380 de 2010.

³ Artículos 10 y 13 Decreto 410 de 1971 Código de Comercio Colombiano

Luego entre 1982 y 1986 el país sufrió una crisis económica que puso a prueba el sistema concursal vigente para la época, no siendo idóneos para tal tarea y verificando que lo que debía buscarse era un mecanismo de solución ágil y que facilitara a las empresas en dificultades el acceso a nuevos recursos de capital sin mayores complicaciones. Frente a ello la entonces Superintendencia Bancaria permitió a los bancos hacer acuerdos privados con sus deudores siendo apalancados por la Junta Monetaria del Banco de la República. Con este mecanismo privado en aproximadamente diez meses se recuperaron más empresas que con los quince años de trámites institucionales vividos hasta ese momento.

De ahí en adelante viene el decreto 350 de 1989, la ley 222 de 1995, luego la ley 550 de 1999 y por último la ley 1116 de 2006 que van decantando y ajustando lo que se fue considerando necesario en su momento y en la medida de las necesidades detectadas, que se siempre se evidenciaron como superficiales para muchos críticos de la materia. Como la gran reforma fue llamada la Ley 1116 de 2.006, estatuto que a pesar de su buena intención y de sus posibles logros, no solamente no corrigió los desaciertos de los regímenes anteriores, sino que los aumentó. Alrededor de ella, y como tratando de corregirle algunos desaciertos, aparece la Ley 1429 de 2010 de generación de empleo y la Ley 1564 de 2012, código general del proceso que incorpora el procedimiento de insolvencia de la persona natural no comerciante que resulta en gran medida insustancial en su aplicación práctica y con vacíos que no se pueden llenar de manera efectiva con la normatividad general existente.

Con el nuevo estatuto queda la sensación de que en su preparación no se tuvo en cuenta la tradición jurídico-institucional del país y que tan sólo se trabajó de manera coyuntural y casuística para los operadores del sistema a costa de la verdadera protección de su organización empresarial, la que necesariamente comporta la de sus actores como son los inversionistas, los terceros, especialmente los trabajadores, y el propio Estado.

Se olvidaron de que en lo instrumental el objetivo del estatuto concursal ha de ser la celeridad, la protección de las partes y el fácil acceso a nuevos recursos. E igual ocurre con las personas naturales no comerciantes que ingresan al proceso de insolvencia y encuentran que, para comenzar se encargan de sus procesos a operadores judiciales que desconocen la forma y el fondo del asunto, y la celeridad brilla por su ausencia, lo mismo que su posible recuperación económica.

Todo ello sumado lo que ha promovido es que aquellos que intentan su recuperación económica y la conservación de los empleos de los trabajadores de buena fe, no lo logren; y en cambio muchos se aprovechen de las mismas circunstancias anotadas burlando a sus acreedores.

Observado lo anterior se adentra ya a lo que se considera necesario plantear en el presente documento y que contiene los temas a tratar que son:

“1) Origen finalístico de la reglamentación sobre insolvencia de persona natural no comerciante en la ley 1564 de 2012 2) Aspectos más relevantes de la ley de insolvencia de persona natural no comerciante y su relación con la ley 1116 de 2006, y 3) Alternativas más efectivas para llenar los vacíos en la aplicación de la insolvencia de persona natural no comerciante, el cual se termina con las conclusiones y recomendaciones del autor”.

En el primer capítulo se pretende encontrar una justificación al origen de la reglamentación de la insolvencia de persona natural no comerciante para el sistema jurídico colombiano en donde, buscando una presentación más clara se desglosa en el referente normativo con sus antecedentes, redondeándolo con legislación relacionada que refuerza la comprensión de lo presentado, concluyendo esta parte con la observación empírica sobre el impacto económico que puede tener la insolvencia.

En el segundo capítulo se hace un recorrido por aspectos de mucha importancia en lo que tiene que ver con la insolvencia en general en una simbiosis con la ley de insolvencia empresarial colombiana, en donde se desglosará, identificando con el uso de literales, la descripción de los antecedentes legislativos de la insolvencia en general y la estructura general o conceptual explicando mediante un resumen lo análogo de la ley de insolvencia empresarial frente a la de la ley de insolvencia de persona natural no comerciante.

Finalmente, en un tercer capítulo se propone hacer un análisis comparativo más exhaustivo entre las normatividades de la insolvencia de persona natural no comerciante frente a la empresarial, en donde se puedan comparar para definir con suficiencia sus falencias y vacíos en la intención de establecer la forma de ser llenados. Para llegar a las conclusiones de este estudio comparativo entre normatividades se pretende describir a partir de tres índices: las diferencias, semejanzas y límites encontrados en todo el contenido del trabajo, lo cual permitirá evidenciar la existencia de parámetros análogos o por el contrario, marcadas brechas que nos permitan señalar quizá, la injustificada existencia de la nueva ley (régimen de insolvencia de persona natural no comercian), o la manifiesta necesidad y justificación de contar con ambas leyes.

En la exposición de tales conclusiones se resalta si necesariamente con la expedición de la ley de insolvencia de la persona natural se resolvió el vacío normativo y coadyuvó con el adecuado tratamiento de la insolvencia del ciudadano del común o, por el contrario, tan solo se limitó a la transcripción analógica del sistema anterior, haciéndolo aún más complejo en su trámite por ser especial, agravando la situación del sujeto para el cual se buscó legislar.

Así las cosas, en lo pertinente al marco de referencia conceptual, el lector encontrará que el eje se basará en distintas normatividades, todas ellas referentes y relacionadas con la insolvencia comercial o empresarial pues es en estos ámbitos que se le ha dado tratamiento práctico y legal a la insolvencia siendo éstas mismas normas y su aplicación las causantes del régimen para la persona no comerciante. Entonces encontramos la *Ley 1116 del 27 de diciembre de 2006*, por medio del cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en Colombia, la *Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso*, en sus artículos 531 y siguientes en cuyos artículos se encuentra reglamentado el Régimen de Insolvencia de Persona Natural no Comerciante, jurisprudencia de la Corte Constitucional, instructivos tanto de las Cámaras de Comercio como de la Superintendencia de Sociedades, así como los actos administrativos expedidos por las autoridades competentes en el tema, por vía de decretos y resoluciones que desarrollan aspectos atinentes a la insolvencia de persona natural no comerciante.

1. ORIGEN FINALÍSTICO DE LA REGLAMENTACIÓN SOBRE INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE EN LA LEY 1564 DE 2012

1.1 REFERENTE NORMATIVO, ANTECEDENTES, Y LEGISLACIÓN

En aras de darle mayor claridad al sustento de las razones que motivaron el desarrollo de la normatividad atinente a la insolvencia de persona natural no comerciante, al revisar los antecedentes legislativos de la misma se ubica dentro de un contexto amplio que rebasa el tiempo a épocas de aplicación básica de las costumbres mercantiles y comerciales que obligan en determinadas circunstancias a la crisis económica de las personas, llevándolas a la imposibilidad de cubrir sus deudas y a sufrir el embate de las ejecuciones de las garantías junto con la limitación material para desenvolverse socialmente.

Es importante advertir al lector, que a pesar de que el eje central de este trabajo es la insolvencia de personas naturales no comerciantes, todo el contenido intelectual, práctico gira alrededor de las normas creadas para el comerciante o la empresa en el entendido que son normas relativamente nuevas y que al final por su misma evolución generaron la inquietud de crear una norma exclusivamente para la persona natural no comerciante.

Todo ello lleva a remitirse a la evolución normativa abordada desde ópticas distintas o con otra connotación, tal como establece el Código Civil en su Capítulo IX, Libro IV, artículos 1672 al 1683 en cuanto al *pago por cesión de bienes*, reglamentado en el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 569 y 570 del Título XXVIII, Libro IV bajo la etiqueta del *concurso de acreedores*, luego derogado por la Ley 222 de 1995.

Tal reglamentación tecnificada en la Ley 222 de 1995⁴ bajo el entendido de los procesos concursales es subsumida en la ley 550 de 1999⁵ bajo el criterio de la reestructuración empresarial, que pretende fomentar el incremento de la economía a partir de la intervención del propio Estado con la intención de garantizar la conservación y recuperación de la empresa, y a su vez, la generación de empleo. Luego entonces aparece la Ley 1116 de 2006⁶ la cual regula el *régimen de insolvencia empresarial*, pero esta vez, excluyendo de manera taxativa a las personas naturales no comerciantes⁷.

⁴ Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones.

⁵ Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley.

⁶ Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones.

⁷ Ley 1116 de 2006 Artículo 3°. Personas excluidas. No están sujetas al régimen de insolvencia previsto en la presente ley: 8. Las personas naturales no comerciantes.

Al ponerse a consideración de las altas cortes algunos elementos de aplicación de la normatividad existente al respecto, y viéndose abocada a darle tratamiento a esa insolvencia no considerada, exhorta al legislador para que se le instituya su propia reglamentación en casos de insolvencia tratando de proteger los intereses de las partes de tal forma que se genere el menor impacto negativo en la sociedad.

En esta aparte resultan de gran ilustración las razones esgrimidas por la Corte Constitucional para reclamar la creación de la norma en comento y que se da en términos como el que sigue

“La decisión del legislador de establecer un régimen de insolvencia específicamente orientado a las empresas y a las personas jurídicas, sin incluir en él a las personas naturales no comerciantes, no es contraria a la Constitución, en la medida en que, por un lado existen diferencias entre los dos conjuntos de personas que son significativas en función de la materia que se está regulando, y por otro, la decisión legislativa atiende a fines importantes, que busca resolver de manera especializada sustrayendo del régimen de insolvencia a aquellos sujetos que no se avienen a las condiciones previstas para el mismo.

La existencia de un imperativo constitucional en relación con un régimen de insolvencia aplicable a las personas naturales no comerciantes tampoco puede derivarse del derecho de acceso a la Administración de Justicia, o del derecho al debido proceso, porque se trata de un régimen complejo que atiende a resolver la situación de los deudores y de una diversidad de acreedores, en un contexto de interés público determinado por la necesidad de preservar el crédito y la actividad económica, y para ello es posible encontrar distintas respuestas jurídicas, cuya definición se desenvuelve en un ámbito de configuración legislativa, sin que quepa imponer como obligados conforme a la Constitución determinados remedios procesales.⁸”

A renglón seguido se ocupa de hacer el exhorto en los siguientes términos:

“Si bien los procesos concursales son, fundamentalmente, mecanismos orientados a la protección del crédito, no es menos cierto que a través de ellos puede hacerse efectivo el principio de solidaridad en aquellos casos en los que, como consecuencia de una situación de insolvencia, el deudor se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que afecte sus derechos fundamentales, razón por la cual resultaría acorde con dicho principio que el legislador estableciese un proceso concursal específico para las personas naturales no comerciantes que se encuentren en un estado de insolvencia.

⁸ Sentencia C-699/07 Recuperado de <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-699-07.htm>

Para tal efecto, la Corte hará un exhorto al Congreso de la República, para que dentro de su potestad de configuración legislativa expida un régimen universal al que puedan acogerse las personas naturales no comerciantes en situación de insolvencia.

El proceso de formación de la Ley “por la cual se establece el Régimen de Insolvencia para persona Natural No Comerciante”, inicia con el proyecto de ley No. 55 de 2008 el día 31 de julio de ese mismo año, con la presentación en la Cámara de Representantes, publicado en la gaceta del Congreso 494 de 2008 y culmina el 25 de enero de 2010 con su promulgación, por medio de publicación en el Diario Oficial 47.603 de esta fecha.

El proyecto original se presentó el 31 de julio de 2008 en la Cámara de Representantes, y se radicó con el número 55 de 2008 Cámara. Este proyecto está conformado por 22 artículos, organizados en dos títulos y en seis capítulos. En el título primero aparece, art. 1 la finalidad, que es la de proteger el crédito y recuperar las finanzas de las personas físicas no comerciantes, por medio de un trámite único de negociación de deudas y, además, proteger la buena fe en las relaciones comerciales; en el art. 2 su ámbito de aplicación es el que corresponde a las personas que tengan su domicilio en el país; art. 3 reconoce una serie de principios orientadores, entre los cuales se destacan los de universalidad, igualdad, eficacia, celeridad, información, buena fe y publicidad; art. 4 establece como supuestos objetivos de la situación de insolvencia: tener dos o más obligaciones vencidas por más de 180 días, siempre que éstas representen el 30% del pasivo total, y éste sea superior a las dos terceras partes del activo total.

Si la persona tiene obligaciones vencidas que representen el 80% del pasivo total, no podrá ampararse en esta ley. Sólo se puede acudir a este trámite una vez cada 6 años; art. 5 y 6 se atribuye competencia a los centros de conciliación del domicilio del deudor, a los cuales faculta para pedir la información necesaria para negociar las deudas; verificar los supuestos objetivos de insolvencia; y elaborar el proyecto de calificación y graduación de créditos.

En el título segundo se regula lo concerniente al trámite de negociación de deudas; la audiencia de verificación de acreencias, conciliación de objeciones y consideración de propuesta de pago; el acuerdo de negociación de deudas; las normas especiales para el pequeño productor agropecuario y pesquero; y las disposiciones finales sobre apoderados, representantes, inexactitud de la información y vigencia. Como resultado de tal pedido, entonces, el congreso de Colombia expide la Ley 1380 de 2010⁹, normativa en la cual, según su objeto y finalidad, le daría al deudor “persona natural no comerciante” la posibilidad de acogerse a un procedimiento que le permitiese, en caso de insolvencia, negociar sus deudas.

⁹ Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia para la Persona Natural No Comerciante

Pero por un error de forma; vicios de procedimiento ocurridos durante el proceso de su formación, dicha normativa no superó el examen de constitucionalidad¹⁰ realizado por la Honorable Corte Constitucional, lo cual llevo a que fuese declarada inexequible.

Enseguida comienza el estudio para intentar unificar los procedimientos en una sola ley, que sin embargo no se cristaliza puesto que aparece entonces la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso, incluyendo en su estructura el Título IV, Libro III, artículos 531 al 576, *Régimen de Insolvencia para Personas Naturales no Comerciantes*, que se pone en marcha con la expedición del Decreto 2677 de 2012¹¹, normativa en la cual se reglamentaron los requisitos que deben cumplir los operadores de la insolvencia para conocer de los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos privados.

Se puede constatar el camino recorrido desde el Código Civil en su Capítulo IX, Libro IV, artículos 1672 al 1683 en lo referente al *pago por cesión de bienes*, el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 569 y 570 del Título XXVIII, Libro IV, sobre el *concurso de acreedores*, la Ley 222 de 1995 de los procesos concursales, la Ley 550 de 1999 de la reestructuración empresarial, Ley 1380 de 2010 y, finalmente, los artículos 531 al 576 del Código General del Proceso que establece el procedimiento de negociación de deudas, convalidación del acuerdo privado y la liquidación patrimonial de la persona natural no comerciante.

En el Código Civil se pretende resolver los conflictos entre deudor y acreedor con la *cesión de bienes*, la cual se entendía como la manera en que el segundo le pagaba al primero con sus propios bienes, intentando entonces que las deudas quedaran saldadas. Ahora bien, de no satisfacerle la obligación principal, si el deudor volvía a adquirir o enajenar bienes a futuro, tendría que cederlos hasta cumplir del todo su obligación.

Esta regla se encuentra en los artículos 1672 al 1682 del Código Civil y en ellos se describen las situaciones a las que puede llegar el deudor frente a su acreedor, lo que nos muestra a primera vista, el primer antecedente legal, cuya relevancia jurídica marcó no sólo la pauta para lo que actualmente se conoce, sino que además se entendía como una herramienta o instituto jurídico, que permitía la posibilidad de honrar sus obligaciones al momento de generarse una controversia con los acreedores, de ahí que uno de los efectos de la llamada *cesión de bienes* sea la extinción de la misma obligación (artículo 1678 ss.).

¹⁰ Sentencia C-685 de 2011

¹¹ Por el cual se reglamentan algunas disposiciones del Código General del Proceso sobre los Procedimientos de Insolvencia de la Persona Natural no Comerciante y se dictan otras disposiciones.

Lo que hasta aquí se puede abstraer es justamente un mecanismo traído desde el derecho romano y acoplado a los códigos napoleónicos, pero que en últimas reflejaban una alternativa bajo el amparo de las propias reglas jurídicas que otrora se traducían como ese abandono voluntario de sus bienes, donde el o los acreedores se pagaban de allí con los frutos de la cosa o incluso era válida la alternativa de venderlos.

Dicho procedimiento se puede ajustar a los términos en que se trabajaba la insolvencia de un deudor, allí eran notorios los estimativos a la buena fe de aquel entrado en mora ante sus obligaciones tal como se observa en el artículo 1674 del código civil: “para obtener la cesión, incumbe al deudor probar su inculpabilidad en el mal estado de sus negocios, siempre que alguno de los acreedores lo exija”.

Después, el Decreto 1400 de 1970 antiguo Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 559 y 560 regla lo pertinente al concurso de acreedores. En éste se establecían dos modalidades del concurso, “el espontáneo” iniciado por el propio deudor, cuando realizaba cesión de todos sus bienes tal como lo indicaba el Código Civil en sus artículos 1672 y ss., pero también se consideraba “forzoso” cuando alguno de los acreedores demandaba en proceso ejecutivo.

En su momento, el legislador estableció para la procedencia en el concurso forzoso, que el deudor estuviera demandado en dos o más procesos ejecutivos donde sus bienes, además de tener medidas de embargo, no alcanzaran para satisfacer la totalidad de las acreencias.

En cuanto al trámite judicial, se seguían las ritualidades del proceso de quiebra, pero el propio artículo 570 del Código de Procedimiento Civil, disponía la manera voluntaria en que el deudor iniciaba el concordato preventivo por medio de un escrito que debía contener la relación del patrimonio adquirido por el deudor, así como también la relación de créditos y garantías que había prestado, además de la relación de aquellos procesos contenciosos que fueran iniciados por parte de sus acreedores, destacando entonces de esta posibilidad, que incluso los acreedores podían coadyuvar el memorial del deudor.

Se ve como entonces, desde ese momento, se generó una ruptura entre la generalidad de la reglamentación civil que trataba la materia y lo específico que se había vuelto a partir de Decreto 2264 de 1969¹², como quiera que ya se comenzaba a reglamentar con un enfoque diferente o especial, orientado esta vez, hacia el universo de las relaciones de los comerciantes.

¹² Por el cual se expide y pone en vigencia el Título de Concordato Preventivo y Quiebra del Proyecto de Código de Comercio.

Con la aparición del Decreto Extraordinario 350 de 1989¹³, que deroga el Decreto 2264 de 1969, resulta oportuno citar su artículo segundo que en su literalidad señala: *“El concordato preventivo tiene por objeto la conservación y recuperación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, cuando ello fuere posible, así como la protección adecuada del crédito”*

Dicha dinámica fue derogada por la Ley 222 de 1995¹⁴ en su artículo 242, toda vez que se hizo necesario reemplazar tales normas por la concreción de un sistema concursal unificado, asunto que en efecto se desarrolló modificando el Libro II del Código de Comercio, incluso, yendo más allá de la posible exclusión cuando se bifurca la insolvencia de una persona civil y la de un comerciante, el artículo 90 de la citada ley estableció que *“(…) los jueces civiles especializados, o en su defecto, los jueces civiles del circuito tramitarán los procedimientos concursales de las personas naturales”*.

Así pues, se encuentra que, hasta ese momento hubiera existido un desamparo ante la situación expuesta, por el contrario, se observa más bien cómo se suprimió dicha figura civil con la Ley 222 de 1995, quebrantando una tradición que procedía desde las propias instituciones del derecho romano.

Aunque el propio sistema jurídico ha sabido enmendar lo que él mismo ha venido derogando, el legislador en aras de reactivar las empresas y reglar su reestructuración promulgó la Ley 550 de 1999¹⁵, aplicable, según lo señala en su artículo primero, *“a toda empresa que opere de manera permanente en el territorio nacional, realizada por cualquier clase de persona jurídica, nacional o extranjera, de carácter privado, público o de economía mixta, con excepción de las vigiladas”*, que sin embargo termina desarrollando más el asunto de la reestructuración empresarial sin dejar ni siquiera la posibilidad de extender dichos procedimientos, o por lo menos, el acompañamiento al sujeto “persona natural no comerciante.

En esa reglamentación no se entendió, o no se quiso tener en cuenta que la persona natural no comerciante es la semilla del sistema económico y por tanto en el evento de cualquier crisis en ese campo es el primer perjudicado; por ejemplo, con la pérdida de su empleo. Lo que queda claro es que tal criterio pasó de largo puesto que tales leyes, la 222 del 95, en su aparte sobre insolvencia, y la 550 de 1999, se plantearon como una solución temporal frente a la crisis existente en su momento, dejando la puerta abierta hacia una unificación de criterios que resolvieran de plano todo el engranaje empresarial en cuanto a la resolución legal de sus crisis.

¹³ Por el cual se expide el nuevo régimen de los concordatos preventivos.

¹⁴ Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones

¹⁵ Ley 550 de 1999. Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley.

En ese camino se expide a Ley 1116 de 2006, estableciendo el Régimen de Insolvencia Empresarial, destacando como su finalidad en el artículo 1°; *“la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo”*, resolviendo con ella muchos de los vacíos legales y procedimentales sufridos a esa fecha, pero dejando nuevamente de lado en su ámbito de aplicación a las personas naturales no comerciantes (Ley 1116 de 2006, Artículo 3, Numeral 8), con la sola excepción del caso de las personas que tengan la condición de controlantes de sociedades mercantiles o que formen parte de un grupo de empresas y cuya insolvencia tenga conexidad con la sociedad mercantil que controlan o del grupo que conforman, de esa forma se aplicarán también las reglas que sobre la insolvencia de grupos prevé el decreto 1749 de 2011¹⁶.

Abogados ahora a la interpretación y aplicación de la Ley 1116 de 2006 se puede ver que el *juez* se convierte en su principal protagonista, ya que además de actuar como conciliador y director del proceso, también cuenta con las facultades apropiadas tendientes a proteger el activo patrimonial del deudor, algo que resulta muy parecido a la extinta figura de los artículos 1672 al 1683 del Código Civil (cesión de bienes), que lleva a sugerir que, con la nueva reglamentación no se ofrece innovación y mucho menos creatividad legislativa, más bien lo anterior, sugiere un nuevo retraso para la sentida necesidad de regulación de la insolvencia de las personas naturales.

Luego entonces, para la segunda legislatura del año 2009, mediante el Decreto 4906 de 2009 el gobierno central instaló las sesiones extraordinarias en el Congreso y posterior a dicho acto se promulgó la Ley 1380 de 2010, que como se ha señalado, fue declarada inexecutable por la Corte Constitucional.

De la citada Ley 1380 de 2010 se deja ver que se sigue brindando al deudor, la posibilidad de iniciar dicho trámite “de oficio”, legitimándole en la causa por activa cuando este se encuentre en cesación de pagos, igualmente de la citada ley se observa que establecía la necesidad de “terceros” denominados *conciliadores*, con las facultades para adelantar el trámite de insolvencia, novedad que hasta esa fecha no había sido observada en anteriores legislaciones pero que tampoco ofrecía un gran avance que justificara *per se* su expedición, puesto que de igual forma, se seguía observando que el juez manejaría el pago por cesión de bienes. Entonces de todo ello lo que se produjo no consistió en una revolución sobre la materia, sino más bien adecuaciones de determinados agentes, pero donde el juez también sería sujeto determinante dentro de dicho esquema.

¹⁶ Artículo 532. Ámbito de aplicación. Los procedimientos contemplados en el presente título sólo serán aplicables a las personas naturales no comerciantes. Las reglas aquí dispuestas no se aplicarán a las personas naturales no comerciantes que tengan la condición de controlantes de sociedades mercantiles o que formen parte de un grupo de empresas, cuya insolvencia se sujetará al régimen previsto en la Ley 1116 de 2006.

Con posterioridad, el gobierno central profirió el Decreto 3274 de 2011 por medio del cual se reglamentó la ley 1380 de 2010, en dicha regulación se asignaron competencias para los encargados de conocer de las solicitudes de *insolvencia de personas naturales no comerciantes*. Sin embargo, al momento de entrarse a estudiar la constitucionalidad de la referida ley, la Corte Constitucional en sentencia C-685 de 2011, el magistrado Humberto Antonio Sierra Porto encontró un vicio en el procedimiento, entendiendo por éste “*aquellas diferencias que se presenten entre lo previsto por el ordenamiento y la actuación del órgano que participa en la elaboración de una ley*”.¹⁷

El asunto lo encontró la Corte tan insubsanable que, en el numeral quinto de su decisión, dispuso. - “*Declarar INEXEQUIBLE la Ley 1380 de 2010, Por la cual se establece el Régimen de insolvencia para la persona natural No comerciante*”, dado que el Congreso en su momento no publicó el Decreto que instauraba las sesiones extraordinarias, siendo así un error que recubría el resto de procedimientos legislativos, incluyendo la ley en su integridad.

Pero el hecho de haber avanzado ya hasta el punto de aprobar el proyecto de ley es de por sí un hecho contundente que no podía quedarse ahí estancado quedando frustrado el camino para ofrecer un salvavidas de tanto impacto para el mundo comercial y económico, entonces el legislador aprovechando el amplio espectro que tenía su proyecto de implementación de un código general de procedimiento decide agregar la regulación sobre la insolvencia de la persona natural no comerciante al interior de la Ley 1564 de 2012, incorporándolo en el Título IV, en sus cinco Capítulos, que van desde el artículo 531 hasta el 576, el régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante.

El Código General del Proceso, en su título final termina consagrando un procedimiento mixto que permite a aquellos deudores que no realizan de forma profesional, pública y habitual una actividad empresarial acceder a un mecanismo similar a aquél que permite a los comerciantes pactar con sus acreedores una reestructuración de sus acreencias y sólo en caso extremo y en sede jurisdiccional ser sometidos a un proceso de liquidación patrimonial, que despliega al final la figura conocida como descargue, nuevo comienzo o “*fresh start*”.

La discusión sobre la necesidad cada vez más apremiante de la inserción de una figura como ésta en los ordenamientos de la familia romano-germánica, se evidenciaba ya desde el año 2001, cuando la Resolución de 26 de noviembre de ese año, expedida por el Consejo de la Unión Europea, relativa al crédito y al sobreendeudamiento de los consumidores, se señalaba que:

¹⁷ Sentencia C-685 de 2011. Corte Constitucional. Honorable Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto

“(…) diez de los Estados miembros de la Unión Europea disponían en ese entonces de una legislación específica relativa a la liquidación colectiva de las deudas de consumidores para ofrecer un tratamiento social, económico y jurídico a los consumidores en situación de sobreendeudamiento excesivo, mientras los demás Estados miembros continuaban aplicando los procedimientos ordinarios (...).

Así mismo, tenemos que, en la misma Guía Legislativa de la UNCITRAL, sobre regulación de insolvencia del veinticinco (25) de junio de 2004, se indica la necesidad que los Estados evalúen el tema de la situación de los llamados “deudores civiles”, siempre desde la óptica del reconocimiento de un “*fresh start*”.

Colombia, no fue ajena a esas discusiones y podemos evidenciar que un poco antes de la guía legislativa y las directrices de la UNCITRAL¹⁸, la Ley 222 de 1995, había optado por realizar una unidad de régimen de insolvencia que permitiera tanto al empresario persona natural o colectiva, como al no comerciante tener acceso, al menos para el último caso, al mecanismo del concordato, permitiendo por esta vía que los consumidores pudieran bajo una misma cuerda procesal renegociar con sus acreedores la forma como inicialmente se encontraban pactadas sus deudas. Esta norma se mantuvo vigente, y con algunas situaciones extremas en su aplicación, hasta la entrada en vigencia de la Ley 1116 de 2006, régimen de insolvencia que de forma expresa en su artículo 3° numeral 8° excluye a las personas naturales no comerciantes de los sujetos que acceden al proceso de Insolvencia en Colombia; volviendo al viejo esquema de entender que la solución universal de este tipo de procedimientos se circunscribía exclusivamente al empresario como sujeto importante del mercado, dado el valor de su organización empresarial y el ser fuente generadora de empleo.

A partir de ese momento, se inicia una afanosa búsqueda de un modelo legislativo que siguiendo los lineamientos de lo señalado en la guía de UNCITRAL y en la Resolución de 26 de noviembre de 2001 expedida por el Consejo de la Unión Europea, culmina con la inclusión en el Título IV del Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, de las normas relativas a una solución específica para la insolvencia del no comerciante. Queda claro entonces el criterio del origen finalístico sobre la reglamentación central objeto de este trabajo. Desde que se derogaron los artículos 1672 al 1683 del Código Civil, el legislativo insistió en gran medida para crear un régimen que tratara la insolvencia de la persona natural no comerciante, llegando incluso con exhortos de

¹⁸ La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, CNUDMI (o UNCITRAL, por su siglas en inglés *United Nations Commission for the Unification of International Trade Law*; en francés *Commission des Nations unies pour le droit commercial international* (CNUDCI)) fue creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2205 (XXI) del 17 de diciembre de 1966 «para promover la progresiva armonización y unificación del derecho mercantil internacional».

la propia Corte Constitucional hasta pasar por la propia inexequibilidad de la misma ley que en su momento intentó abordar el asunto¹⁹, hasta la inclusión del procedimiento en la Ley 1564 de 2012, reglamentado por el decreto 2677 del mismo año en donde se vislumbra el afán por proteger al consumidor raso que representa en esencia el fondo o la base de los grandes comerciantes sustentados en las entidades crediticias y financieras que promueven el acceso a los capitales y que, como se puede comprobar en los casos prácticos a presentar en la última parte del presente texto, son el porcentaje mayoritario de los acreedores afectados por la cesación de pagos de tales personas.

1.2 CONSIDERACIONES DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LA INSOLVENCIA

Para tratar este tema, que es la raíz del problema en cuestión, al tiempo que su misma esencia que obliga su direccionamiento hacia la mejor solución, la Superintendencia de Sociedades le da una presentación mecanizada, sistemática y técnica de acuerdo con la naturaleza de la entidad y su fin institucional dentro de la introducción a su curso virtual sobre insolvencia de persona natural no comerciante.

Comenzando con un aspecto económico, como bien lo propone Tosí (2004)²⁰, al afirmar que:

“La teoría de los mercados dice que las unidades económicas menos eficientes, comienzan a perder esa zona de ganancia que recorre el costo marginal hasta el precio marginal, se igualan y finalmente cuando el costo supera el precio la unidad se torna inviable”.

Con este antecedente o situación empresarial, comienza entonces la condición de la insolvencia, entre tanto se gesta a partir de un desequilibrio económico, administrativo y financiero, en el que para el empresario se hace insostenible el cumplimiento de sus obligaciones, conduciéndolo al cese de pagos y posteriormente al incumplimiento con sus acreedores, hechos que llevan a que autores como Broseta (1983)²¹, exprese que dicho incumplimiento se perfila como fenómeno de naturaleza jurídica que se puede considerar como un “estado” de impotencia del patrimonio, un concepto debatido desde la doctrina económica y del derecho económico.

En el marco de estos planteamientos, algunos autores como Satta (1951)²² interpretan que la insolvencia se constituye gracias a la existencia de un desequilibrio aritmético entre el activo de la empresa y su pasivo; y en

¹⁹ Piedrahita, E (2015). *Ley de insolvencia de personas naturales no comerciantes: estudio analítico a partir de la ley 1116 de 2006. diferencias, similitudes y límites*. Universidad Católica de Colombia, Bogotá Recuperado de <http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2158/1/TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf>

²⁰ TOSI, Francisco. (2004). *Hacia una teoría de la responsabilidad empresarial ante la insolvencia*.

²¹ Primera Edición. Buenos Aires, Argentina: Universidad Católica de Buenos Aires. Págs.12-13 9 BROSETA,

²² SATTA, Salvatore. *Instituciones del Derecho de Quiebra*. Editorial EJEA, Buenos Aires, 1951, p. 58

contraposición a esta definición, se afirma que tanto el cese de pagos como la insolvencia son sinónimos, en razón de la imposibilidad jurídico legal de hacer una revisión general de los libros de la empresa, sin contar, por otra parte, con que el crédito comercial traduce capital incierto disponible (Argeri, 1983)²³.

Con estas dos tendencias, es fundamental conocer la base dogmática que da pie a la insolvencia –como estado financiero en Colombia-, y por ello es de anotar que respecto a la sinonimia entre la cesación de pagos y la insolvencia existen dos corrientes doctrinales. La primera que los concibe como estados iguales y la segunda que establece que no son lo mismo, siendo Satta el principal defensor de la sinonimia, y contradicho en los años 70 por la escuela francesa, quienes, a partir de la postguerra, le dieron a la cesación de pagos un valor superior al mero incumplimiento.

*En Italia, en 1942 se modificó este punto al abandonar la cesación de pagos como extremo para la quiebra y tomar con igual fin la insolvencia; y de esta solución se ha dicho que se eliminó uno de los mayores tormentos doctrinarios y exegéticos y se adaptó el espíritu del código anterior a la dicción literal de la actual norma legal. Así, el estado de insolvencia se manifiesta por el incumplimiento de una o más obligaciones, u otros hechos exteriores demostrativos de la impotencia patrimonial para cumplir con las deudas exigibles, sin consideración al carácter de dichas deudas.*²⁴

Basados en lo anterior, la cesación de pagos es la manifestación externa de la insolvencia o la insolvencia es la causa de la cesación de pagos, es decir, que es un hecho externo que revela el estado de insolvencia, es un estado de hecho que es fundamental para crear una situación de derecho: la declaratoria de falencia (quiebra o insolvencia) del deudor, o sea, es un estado de hecho que se expresa por el estado jurídico de un patrimonio que está impotente para hacerle frente a los compromisos, es la expresión actuante del estado de insolvencia.

En esta línea, la insolvencia para efectos de esta monografía puede entenderse como el estado jurídico del patrimonio impotente para satisfacer las deudas vencidas y las que están por vencerse, aunque vale la pena afirmar que una de las principales críticas que se les ha dado a las investigaciones donde la insolvencia económica ha sido objeto de estudio, es la inexistencia de un consenso sobre el concepto de insolvencia, que se restringe en la mayoría de estudios, al criterio legal de quiebra y suspensión de pagos.

²³ ARGERI, Saúl. Manual de Concursos. Buenos Aires: Editorial ASTREA, 1983, págs. 25-26

²⁴ http://sitios.poderjudicial.go.cr/escuelajudicial/archivos%20actuales/documents/revs_juds/rev_jud_82/articulos/articulos8.htm#1

Es así que para finalidad de este trabajo, el concepto de insolvencia sea entendido como el conjunto de hechos reveladores de la contabilidad, ya sea desde su constitución como sociedad o como persona natural, y es dentro de estos hechos que se pueden evidenciar incumplimientos, fuga, cierre de los establecimientos de comercio, y otros que constituyan la cesación de pagos que refleje una impotencia, pues sólo se está en presencia de cesación de pagos demostrativa de la insolvencia cuando el patrimonio del deudor se resiste, por imposibilidad de satisfacer las obligaciones.

Del mismo modo, para el caso colombiano, bien se puede afirmar la vigencia en su normograma²⁵, que a pesar de ser una postura previa a la transformación económica que se sufrió en América e incluso en Europa y Asia en los años 70, bien refleja las bases colombianas en torno al estado de insolvencia, entre tanto indica este es un estado patrimonial definitivamente malo; pero la quiebra puede producirse existiendo o no insolvencia, entre tanto:

Ésta – la insolvencia - es un hecho independiente y ajeno de aquélla, ya que, en muchos sistemas, la quiebra no se basa en la insolvencia sino en la simple cesación de pagos, como hecho demostrativo del estado patrimonial desastroso del deudor. Quien incurre en cesación de pagos, por esto puede considerarse en estado de quiebra, no tiene por qué ser insolvente necesariamente; para estar en cesación de pagos basta con no cumplir una obligación, a pesar de tener un gran activo superior al pasivo. Y también puede ser insolvente sin tener deudas impagas, no poseyéndose nada, pues no es insolvente quien tiene muchas deudas solamente, ya, por ejemplo, puede pagarlas y quedarse sin nada. (Varangot, 1959)²⁶

(...) sectores doctrinarios han sostenido que una persona natural o jurídica puede ser catalogada de insolvente, incluso en el caso de que sus activos totales sean superiores al valor de la suma de sus deudas. Esto ocurre si el pasivo exigible a corto plazo es mayor a su activo disponible o liquidable. En consecuencia, interesaría la capacidad de realizar sus bienes, vale decir, de convertir rápidamente sus activos en efectivo para hacer frente a sus obligaciones de pago. Es lo que se conoce como liquidez.

Por último, resulta fundamental distinguir entre la insolvencia real y la ficticia o aparente, pues mientras en la primera el patrimonio del deudor efectivamente se hace insuficiente para satisfacer sus compromisos, en la segunda el deudor finge una merma importante en su patrimonio (como en la ocultación maliciosa de bienes) la que le impide cumplir con las obligaciones contraídas (Bitran, 2008)²⁷

²⁵ Determinamos como normograma a aquel conjunto de normas que fueron surgiendo cronológicamente como reguladoras de la insolvencia; tanto desde el surgimiento del Decreto 750 de 1940 hasta la puesta en firme de la Ley 1564 de 2012.

²⁶ VARANGOT, Carlos Jorge. Manual de Quiebras. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1959, pp. 285- 286

²⁷ Bitran, Y. (2008). Insolvencia punible. Análisis y propuestas para una reforma. Santiago de Chile: Universidad de Chile.

Ahora, clara la base dogmática de la insolvencia y el hecho de que ésta puede gestarse tanto para personas naturales como para personas jurídicas, es momento de adentrarse en su impacto económico, citando para fines prácticos, de manera breve la categorización que desde el campo jurídico y económico cubija el estado de insolvencia económica.

Luego de hacer el recorrido sobre los antecedentes de lo establecido en la Ley 1564 de 2012 para insolvencia, en el documento mencionado se plantea el sobreendeudamiento como un detonante de la crisis del deudor señalando que “El fenómeno descrito genéricamente como “Sobreendeudamiento” se traduce en una desafortunada situación de deudas excesivas sin la capacidad del deudor de hacer frente a ellas con las rentas ordinarias.

Este fenómeno se traduce en una desafortunada situación de deudas excesivas sin la capacidad del deudor de hacer frente a ellas, es decir, “a un conjunto de pagos concatenados en el tiempo cuyo reembolso no puede ser atendido por las rentas ordinarias de un consumidor”²⁸, y que ha sido descrito genéricamente como sobreendeudamiento²⁹.

Lejos de ser un problema de orden privado, afecta de manera directa el orden público económico al generar un impacto negativo considerable a nivel macroeconómico. El aumento exponencial y desmesurado de la deuda como consecuencia de la flexibilidad de las entidades financieras y de la ausencia de información por parte de los deudores al momento de tomar un crédito, hace que el sistema jurídico se preocupe por dar una respuesta oportuna y eficaz ante dicha realidad.

Es necesario establecer que el sobreendeudamiento no es insolvencia, sino un estadio previo a ella que de no regularse conducirá a ella y que por tanto exige ser atendido de manera preventiva. De otra parte, el sobreendeudamiento encuentra su origen en la incapacidad sobrevenida y la adicción al consumo.

²⁸RIBÓN SEISDEDOS, Eugenio. *El consumidor ante la crisis económica: análisis y soluciones*. CEACCU, Madrid, 2011. p. 7.

²⁹ “Hablar de endeudamiento excesivo o de sobreendeudamiento es hacer referencia a situaciones en las que el deudor se ve en la imposibilidad, de forma duradera, de pagar el conjunto de sus deudas, o expuesto a una amenaza seria de no poder hacerles frente en el momento en que sean exigibles (...). El concepto de sobre- endeudamiento que subyace a las más variadas iniciativas reguladoras se deriva esencialmente de las disposiciones jurídicas que fijan las condiciones de acceso a cualquier procedimiento de reestructuración del pasivo, de tipo tanto judicial como extrajudicial. Así pues, por ejemplo, el Derecho francés admite el acceso a los deudores de buena fe que se vean en «la imposibilidad manifiesta de hacer frente al conjunto de sus deudas profesionales vencidas o a vencer» (artículo L.331 - 2 del Código de Consumo). Del mismo modo, la legislación finlandesa (1993) considera sobreendeudado o insolvente al deudor que no esté en condiciones de pagar sus deudas cuando sean exigibles; esta incapacidad debe ser permanente y no solamente accidental o transitoria. Sin embargo, otros países se limitan a definir un conjunto de requisitos procedimentales y personales para el acceso a los regímenes que abordan el sobreendeudamiento, sin arriesgarse a dar una definición de esta figura. Es el caso del Derecho belga (ley de 5 de julio de 1998, modificada por la ley de 19 de abril de 2002) y del Derecho norteamericano (Bankruptcy Código, en su revisión de 2005)”. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “El crédito y la exclusión social en la sociedad de la abundancia” de 16 de febrero de 2007, p. 76.

La primera hace referencia a una situación que ha sido denominada por la doctrina como el “sobreendeudamiento pasivo”, donde el deudor no puede hacerles frente a las deudas debido a contingencias sobrevenidas que afectan de manera considerable su capacidad económica, por ejemplo, por pérdida del empleo, el divorcio, accidentes o enfermedades graves. Por otro lado, la adicción al consumo o “sobreendeudamiento activo”, hace referencia a la asunción excesiva de deudas, que usualmente se encuentra ligada a la carencia de formación financiera o de cultura financiera del deudor.

Se trata de situaciones en las cuales los deudores consumidores son seducidos por las campañas publicitarias y la inmediatez del dinero en las tarjetas de crédito. El sistema económico capitalista pretende asegurar que exista consumo y para ello es necesario establecer la capacidad de endeudamiento, tener endeudamiento forma parte de la vida contemporánea. En este sentido, el crédito representa una serie de ventajas al mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de cualquier orden social. Así lo ha manifestado el Comité Económico y Social Europeo al establecer que el deudor aislado de hoy es el esclavo de la antigüedad”.

Hasta aquí se observa como el mismo sistema económico de mercado consumista, profundizado por la ignorancia financiera o la misma adicción enferma a ese consumo produce la problemática que se intenta solucionar, y continúa diciendo que: “Ahora bien, resulta necesario combatir por su existencia y desarrollo bajo condiciones de viabilidad que no degeneren en un sobreendeudamiento nocivo para en perjuicio del sistema económico y financiero.

En estrecha conexidad con lo anterior, se han estructurado sistemas de financiación pensados más en la posición de la entidad y en la conquista de un mercado que en la verdadera capacidad de pago del deudor como una sobre oferta de tarjetas de crédito, de créditos de consumo, de compra de cartera y en general en una fascinación por el endeudamiento como justificación del consumo... ..Se trata principalmente de un espacio de negociación propio de los mecanismos de insolvencia recuperatorios con miras a definir nuevas reglas para la atención del pasivo insatisfecho. Deben ser mecanismos acordes con la situación patrimonial del deudor y que le permitirán en un tiempo determinado normalizarlas y seguir interviniendo en el tráfico económico sin restricciones”³⁰.

Queda claro que la mejor aplicación de la norma lo que finalmente busca es la recuperación económica del deudor como actor del sistema económico previniendo con ello la continuidad del desarrollo mercantil en buenas condiciones para el mantenimiento de los sistemas económicos de la sociedad.

³⁰ Superintendencia de Sociedades (2017). *Introducción al tema de insolvencia*. Curso Virtual: En insolvencia para persona natural no comerciante Recuperado de <http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/Introduccion-cursovirtualinsolvencia.pdf>

Por otro lado, y en la misma línea conceptual, el tratadista sobre insolvencia Juan José Rodríguez Espitia en su libro “Régimen de Insolvencia de Persona Natural No Comerciante, en el apartado crisis, procedimientos y descargue: los cimientos del nuevo régimen de insolvencia de persona natural no comerciante³¹” hace un listado de apartes acerca del sobreendeudamiento, de entre las que se extraen algunos de ellos.

“Una de las preocupaciones actuales de la doctrina concursal comparada es la insolvencia del deudor o el sobreendeudamiento de los consumidores. El aumento exponencial y desmesurado de la deuda como consecuencia de la flexibilidad de las entidades financieras y de la ausencia de información por parte de los deudores al momento de tomar un crédito, hace que el sistema jurídico se preocupe por dar una respuesta oportuna y eficaz ante dicha realidad. En efecto, se ha registrado un notable aumento del número de deudores en quiebra a tal punto que los niveles de endeudamiento resultan alarmantes.

Se trata de un concepto que no resulta unívoco y cuya definición y contenido se fija por cada ordenamiento, que guarda una estrecha conexidad con las crisis financieras y la imposibilidad del retorno a una tasa de crecimiento económico sostenible. En este sentido, lejos de ser un problema de orden privado, afecta de manera directa el orden público económico al generar un impacto negativo considerable a nivel macroeconómico. Así mismo, la forma de medir el endeudamiento excesivo se configura como uno de los principales problemas que ostentan los analistas económicos debido a las divergencias metodológicas y a la falta de estadísticas fiables.

No obstante, es necesario establecer que el sobreendeudamiento no es insolvencia, sino un estadio previo a ella que de no regularse conducirá a ella y que por tanto exige ser atendido de manera preventiva. Si bien se trata de un fenómeno que no es nuevo ni exclusivo de la sociedad contemporánea, el origen del sobreendeudamiento debe buscarse en dos fuentes principales: la incapacidad sobrevenida y la adicción al consumo. Se trata de una situación que ha sido denominada por la doctrina como el sobreendeudamiento pasivo, donde el deudor no puede hacerles frente a las deudas por pérdida de empleo, accidentes, enfermedades. Se trata de contingencias sobrevenidas que afectan de manera considerable la capacidad del deudor, impidiendo el cumplimiento oportuno de sus obligaciones.

Por otro lado, la adicción al consumo, o sobreendeudamiento activo, hace referencia a la asunción excesiva de deudas, que la más de las veces va sumada a la inexistencia de formación financiera o si se quiere a la falta de cultura financiera del deudor.

³¹ Rodríguez, J (2013). *Crisis, procedimientos y descargue: Los cimientos del nuevo régimen de insolvencia de persona natural no comerciante*. Recuperado de <https://letrujil.files.wordpress.com/2013/09/15juan-jose-rodriguez.pdf>

Se trata de situaciones en las cuales los deudores consumidores son seducidos por las campañas publicitarias y la inmediatez del dinero en las tarjetas de crédito, generando un sobreendeudamiento que no pueden atender.

Siguiendo esta línea de pensamiento conviene resaltar que el sistema económico en el mundo capitalista se encuentra soportado sobre tres bases: producción, consumo y crédito. Bajo esa medida, el sistema pretende asegurar que exista consumo y para ello es necesario establecer la capacidad de endeudamiento. En este sentido, el ser consumidor equivale a formar parte del sistema de crédito, el tener endeudamiento forma parte de la vida contemporánea y responde a un modelo impuesto por la sociedad y las economías poderosas, muchas de las veces implacable con el individuo.

En este aspecto, el ser sujeto de crédito y el estar en una base de datos forma parte de ser considerado como persona en el mundo actual. Por ello, se torna imperioso adoptar medidas para obtener dicho propósito, pues el crédito posee la virtualidad de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de cualquier orden social, punto sobre el cual se ha pronunciado el Comité Económico y Social Europeo al establecer que el deudor aislado de hoy es el esclavo de la antigüedad, el que pagó con su libertad el incumplimiento y hoy más, un prisionero en vida de un sistema que lo invitó a sobre endeudarse y que luego lo excluye.

Haciendo una síntesis de lo planteado sobre este tema, resulta interesante advertir la frase escrita por el tratadista que dice "...el ser sujeto de crédito y el estar en una base de datos forma parte de ser considerado como persona en el mundo actual", que suena muy materialista, pero es real e inevitable.

Partiendo de esa premisa entonces la existencia misma de la persona es ya una causal de crédito que tiene altas probabilidades de no ser pagado y por tanto ingresar a la naturalidad de la insolvencia tomando esto como la raíz de la problemática planteada en términos de lo que socialmente significa ese impacto económico positivo, cuando se logra una negociación de deudas, o negativo, cuando se tiene que liquidar el patrimonio.

Como se ha expuesto a lo largo de este trabajo, el impacto económico de la insolvencia sobre la sociedad es directamente proporcional a la situación o estado del mismo sistema social frente a la competencia, si el momento económico es positivo, se presentan muchos menos casos de insolvencia y frente a los casos presentados por lo general mayores probabilidades de acuerdos de pago; contrario a los momentos de crisis económica generalizada, cuando aumentan los casos de insolvencia y de igual forma mayores casos no resueltos a favor del deudor y por ende mayor cantidad de liquidaciones patrimoniales.

De cualquier manera, si se aprueba la negociación de deudas, en el caso de la persona natural no comerciante, o el acuerdo de pagos, en el caso del comerciante o empresa; se va a generar la recuperación de la confianza del deudor para continuar produciendo y aportando así al desarrollo económico y social.

Pero si no se aprueba, en ninguno de los dos casos, igualmente el deudor tiene la posibilidad de la liquidación judicial o descargue de obligaciones que le van a permitir, en un tiempo relativamente corto reintegrarse al aparato productivo en condiciones adecuadas al mercado y por tanto también continuará produciendo riqueza y desarrollo: Conclusión, los estatutos sobre insolvencia representan un aporte muy importante al desarrollo socioeconómico, por tanto, su impacto siempre será positivo.

Miremos una observación hecha dentro una presentación sobre el tema de insolvencia de persona natural no comerciante de la Superintendencia Financiera que resalta unos datos históricos que vale la pena tener en cuenta puesto que los créditos de la mayoría de las personas son obtenidos con entidades bancarias o financieras convirtiéndose éstas en los principales acreedores actuantes en los diferentes procesos.

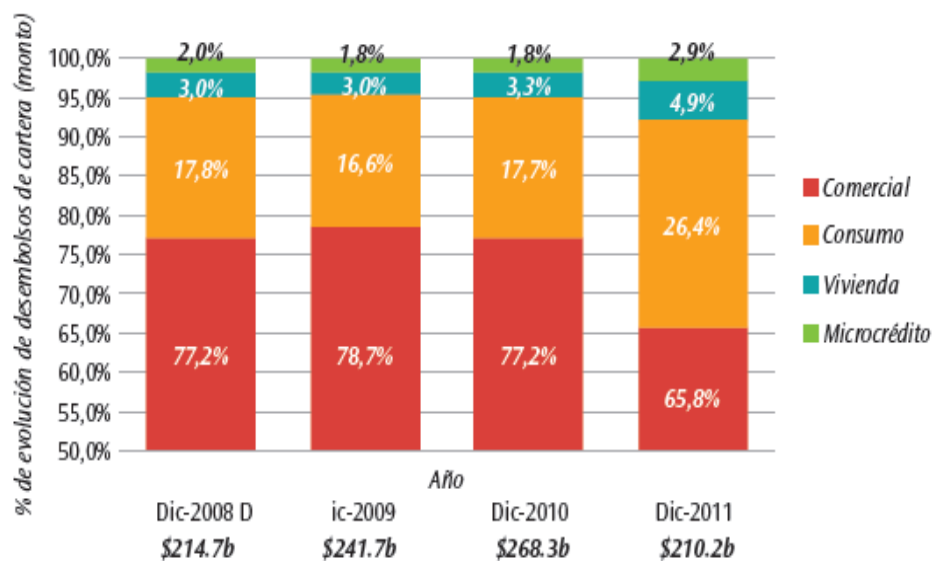
A pesar de que la Superintendencia no tiene un papel activo dentro del proceso de insolvencia que creó la Ley 1564 de 2012, es importante resaltar que un gran número de personas tiene pasivos con el sector financiero.

Las carteras de consumo, vivienda y microcrédito han incrementado su participación en el total de desembolsos por las siguientes razones:

- Dinamismo en el crédito de consumo.
- Programas de política pública enfocados a promover el crédito de vivienda y el microcrédito.
- Conversión de entidades.
- Tendencia creciente de la tasa de interés de colocación del microcrédito.

Aunque los bancos son las entidades más importantes en la oferta de productos activos y pasivos, se resalta la importante participación de las ONG en la colocación de microcrédito —dada su especialidad en este nicho— y de las Cooperativas SES en consumo, tanto por el gran número de entidades como por su enfoque en este tipo de cartera (particularmente en crédito de libranza).

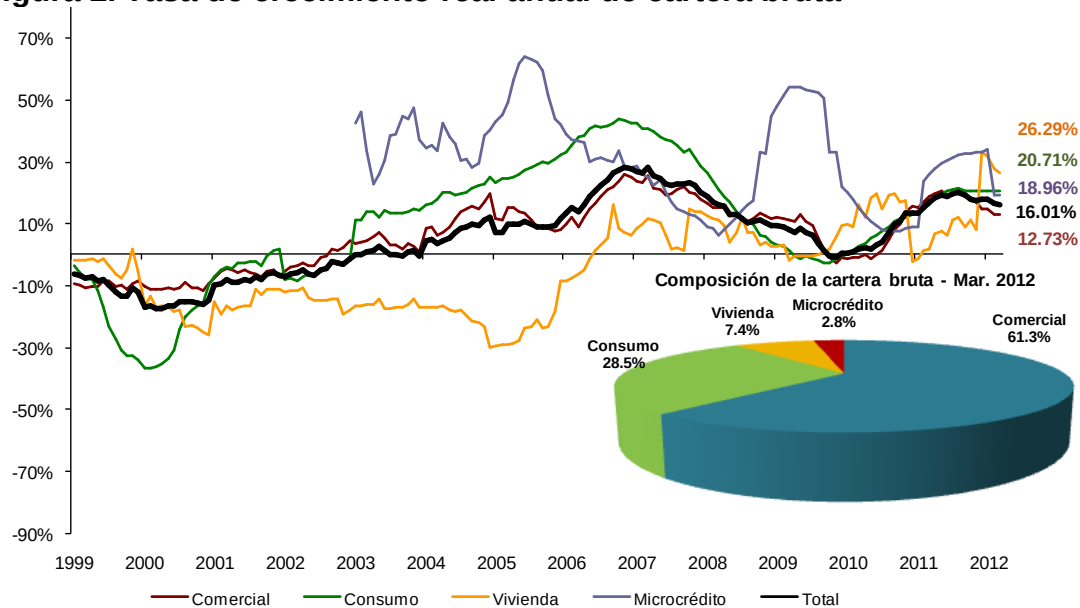
Figura 1. Evolución de desembolsos de cartera



Fuente: Superintendencia Financiera

Las mayores contribuciones al crecimiento de la cartera fueron realizadas por las modalidades comerciales y de consumo, las cuales representan el 90% del saldo total. Por su parte, las carteras de vivienda y de microcrédito presentaron tasas de crecimiento real de 26.29% y 18.96%, respectivamente.

Figura 2. Tasa de crecimiento real anual de cartera bruta



Datos hasta marzo de 2012. Cartera y operaciones de leasing de los establecimientos de crédito con cooperativas. No incluye IOE.

Fuente: Superintendencia Financiera

Debe precisarse entonces que la mayoría de las personas tienen obligaciones con las entidades financieras, este mecanismo busca encontrar un equilibrio que permita a las personas naturales renegociar sus pasivos, como a los acreedores instrumentos que faciliten la recuperación de dichos recursos. La SFC realiza el seguimiento de la cartera bruta y vencida que los consumidores financieros deben a las entidades vigiladas dada la importancia que ello tiene para la estabilidad del sistema financiero. Resulta esencial continuar con dicho seguimiento por cuanto el proceso de insolvencia de persona natural puede acarrear cambios en el pago de las obligaciones, así como modificaciones en el índice de cartera vencida.

La justificación del sistema económico en la forma descrita ha conllevado a una serie de arremetidas frente al deudor, una seducción constante y completa a consumir, ya casi irresistible. De este modo, sin perjuicio de la multiplicidad de ventajas que puede reportar el acceso al crédito dentro del sistema económico, resulta indispensable propender por su existencia y desarrollo bajo condiciones de viabilidad que no degeneren en un sobreendeudamiento nocivo para el mismo.

Así mismo y en estrecha conexidad con lo anterior, se han estructurado sistemas de financiación pensados más en la posición de la entidad y en la conquista de un mercado que en la verdadera capacidad de pago del deudor como una sobre oferta de tarjetas de crédito, de créditos de consumo, de compra de cartera y en general en una fascinación por el endeudamiento como justificación del consumo. “Confrontan así los dos polos del sistema económico: el poder productor, generador de riqueza, a través de la empresa constituida en el motor de la economía y por el otro lado el consumidor, destinatario de la producción y de la distribución, sujeto aislado que precisamente incentivado en su función por el ente productor y distribuidor de bienes y servicios asume magnitud destinada a consolidar la demanda de aquellos en forma tal que paulatinamente pasa a constituir una masa inmensa, subordinada como parte débil de una relación jurídica, merecedora de protección cuando el consumo se convierte en el calificativo de toda una sociedad provocando el inicio de tres nuevos conceptos: la “sociedad de consumo”, la “economía de consumo” que demandarán un nuevo derecho, el “derecho del consumo” y hoy el “derecho del consumidor sobre endeudado”³².

Las circunstancias descritas han llevado a considerar no sólo la necesidad de un régimen para la persona natural no comerciante, o si se quiere para el consumidor o deudor no empresario, sino además la creación de un mecanismo flexible y que ahorre tiempo y dinero, sumado a una serie de medidas asistenciales o administrativas que honren su condición personal y le permitan superar en algunos casos una adicción al endeudamiento propia del sistema económico capitalista.

³² ANGEL DASSO, Ariel. *La exaltación del consumo y el derecho del consumidor al procedimiento concursal*. En “*La composizione delle crisi da Sovraindebitamento*”. Roma, 7-8 giugno 2012, p. 4.

Estas últimas expresiones pueden resultar excéntricas en el Derecho colombiano. Sin embargo, es menester tenerlas en cuenta pues en países desarrollados no sólo se protege al consumidor frente a la insolvencia, sino que a dicha protección se suma el diseño de mecanismos que realcen su condición personal y en especial los derechos fundamentales que el mismo ordenamiento les reconoce.

No se pretende desconocer el consumo, su necesidad, su papel en el sistema económico, al igual que el crédito al cual va unido, pero sí hacer un llamado a su ponderación, a su real dimensión, a su compatibilidad con la naturaleza humana, a reconocer su desviación o adicción como una verdadera patología y en especial a hacerlo más humano y digno del hombre. En este sentido, resulta pertinente establecer una serie de medidas en pro de su prevención, verbigracia información más completa y con mayor divulgación, educación financiera, crédito social y crédito asequible, creación de redes de servicios de asesoría financiera, incentivos de ahorro y un crédito responsable.

Así mismo, debe destacarse el esfuerzo de varios ordenamientos por impulsar un proceso de desendeudamiento con el fin de lograr un crecimiento económico sostenible. En concordancia con lo anterior, la expedición de una serie de estatutos a nivel internacional es evidencia del interés de los ordenamientos por regular la situación de los consumidores financieros y su protección. Así mismo, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, la expedición de la ley 1328 de 2009³³ denota una gran preocupación por el cumplimiento de obligaciones de información de las entidades financieras frente a sus consumidores. Sin embargo, dicho proceso ha sido lento y arduo, no obstante contar con las regulaciones pertinentes.

Se han planteado una serie de medidas curativas frente a la situación de sobreendeudamiento de los consumidores, entre las cuales se encuentra la renegociación de la deuda, la reorganización judicial de la deuda y el reembolso anticipado. Por un lado, la renegociación de la deuda implica una aproximación del deudor a su acreedor con el fin de modificar por mutuo acuerdo las condiciones de la deuda. Esta medida se acompaña de cláusulas en los contratos de crédito donde es posible suspender el pago de cuotas en ciertos períodos donde el deudor se encuentre en difícil situación financiera y no pueda atender sus obligaciones. Sin embargo, en el fondo lo que se genera es una financiación adicional, que de manera indirecta genera los mismos efectos que pretende combatir. En el fondo, y a largo plazo, lo que se genera es un agravante en el nivel de endeudamiento.

Por otro lado, como ocurre en la legislación francesa, la reorganización judicial de la deuda hace referencia a la posibilidad del deudor de acudir a una autoridad para que ésta le otorgue un plazo adicional para el cumplimiento de su obligación. Sin embargo, debe recalcar que son pocos los casos en los que se

³³ Ley 1328 de 2009 por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones. (Del régimen de protección al consumidor financiero)

puede presentar esta medida preventiva a la situación de insolvencia. Por último, como medida preventiva se ha contemplado el reembolso anticipado, situación que ha sido discutida por el sector bancario en Colombia. Esta medida parte de la base de reducción de costos por la inexigibilidad de los intereses no devengados. En este sentido, la ley 1555 de 2012 permitió al consumidor prepagar su deuda sin incurrir en ningún tipo de sanción o sin necesidad de pagar los intereses no devengados³⁴.

Luego de establecer el porqué de la necesidad de establecer regímenes que respondan a situaciones de crisis, resulta indispensable determinar cuál es la naturaleza de los procedimientos que adoptó el legislador para afrontar dicha situación. Ahora bien, los instrumentos para el manejo de la insolvencia de la persona natural no son unos mismos, en algunos casos se optan por mecanismos judiciales, en otros administrativos e incluso asistenciales, referidos más a las normas de protección del consumidor³⁵ o autoridades dispuestas para proteger sus derechos, que a normas de insolvencia.

Ello corrobora la dificultad en adoptar soluciones de un mismo tipo, dada la diversidad de los asuntos y en especial su vinculación a contenidos económicos de mayor calado que trascienden la esfera individual y tienen un matiz colectivo o de interés general.

Un primer aspecto a considerar consiste en el deseo del legislador de implementar un instrumento distinto al previsto para el manejo de la insolvencia de la empresa, con lo que se pone de presente el reconocimiento que la insolvencia de la persona natural no comerciante merece un trato distinto que responda a los particulares intereses que se encuentran en juego, verbigracia las obligaciones alimentarias a cargo del deudor y los derechos fundamentales que se encuentran en juego.

Un segundo aspecto responde al hecho que la solución implementada por el legislador no tiene antecedentes en Colombia para el manejo de la insolvencia, bien sea de la empresa o de la persona natural no comerciante.

Sobre el particular es necesario indicar que tradicionalmente la insolvencia ha sido deferida a instrumentos de naturaleza judicial como el concordato preventivo, el concurso de acreedores y el proceso de reorganización, de manera que la ley 550 de 1999 constituye un antecedente distinto al consagrar un instrumento de naturaleza contractual para el manejo de estos asuntos.

³⁴ Artículo 1 ley 1555 de 2012. “Adiciónese al artículo 50 de la ley 1328 de 2009 el siguiente literal: g) Efectuar pagos anticipados en toda operación de crédito en moneda nacional sin incurrir en ningún tipo de penalización o compensación por lucro cesante, de las cuotas o saldos en forma total o parcial, con la consiguiente liquidación de intereses al día del pago”.

³⁵ El ordenamiento jurídico colombiano ha demostrado un reciente interés por la situación jurídica del consumidor y su protección, razón por la cual ha expedido una serie de regulaciones en aras de su protección, a saber el nuevo Estatuto de Protección al Consumidor (ley 1480 de 2011) y el Régimen de Protección al Consumidor financiero (ley 1328 de 2009).

En este sentido, la solución adoptada, es decir, el régimen soportado en un mecanismo conciliatorio no tiene antecedentes en Colombia, máxime si se toma en cuenta que la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos³⁶ ha sido utilizada tradicionalmente para definir asuntos de naturaleza bilateral y no propiamente como herramientas para conseguir acuerdos con acreedores de manera colectiva, aun cuando han existido ejercicios aislados de alguna importancia, pero referidos a empresas y no a personas naturales.

Cabe preguntarse entonces ¿por qué se adoptó la conciliación como eje del mecanismo? La respuesta a este interrogante parece encontrarse en el número reducido de acreedores del deudor persona natural no comerciante, que haría viable este tipo de soluciones. De igual manera, la demora en el trámite de los concordatos de personas naturales bajo la vigencia de la ley 222 de 1995 permite justificar la decisión de descartar su continuidad o de contemplar un sistema similar.

La posibilidad del deudor para normalizar el pasivo debe responder a la voluntad inquebrantable de honrar a sus acreedores, acceder a condiciones que le permitan superar el impase temporal por el que se encuentra, más a que a la naturaleza del instrumento; incluso pensando en razones de tiempo la conciliación por el número de acreedores, la naturaleza de las obligaciones y la ausencia de trabajadores, por ejemplo, impone considerar que el instrumento conciliatorio podría resultar más que adecuado.

La finalidad del nuevo régimen va más allá de la atención de las obligaciones y bajo esa premisa se establecen reglas que aseguran su reintegración al sistema económico. De este modo, se dispone el inicio del cómputo de caducidad del dato negativo a partir del año siguiente al inicio del proceso de liquidación patrimonial.

El ordenamiento ha establecido como derecho fundamental el *habeas data*, el cual ha sido definido por el legislador como “el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, particularmente en relación con la información financiera y crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países” (art. 1 ley 1266 de 2008). Se establece en cabeza de los particulares un derecho a controlar y rectificar la información que centrales de información han recopilado sobre ellos.

³⁶ Art. 64 ley 446 de 1998. “La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador”.

Así mismo, la jurisprudencia nacional ha precisado que el dato negativo no puede permanecer de manera indeterminada en las bases de datos, cuenta con límites determinados, dando lugar a lo que se ha denominado un *derecho al olvido*³⁷. A través de la caducidad del dato negativo se le da la oportunidad de la frustración del mecanismo recuperatorios. Esta regla se justifica por varias razones. Por un lado, pretende desestimular el ejercicio de los deudores para acudir directamente al descargue, respondiendo a la tendencia de que el descargue vaya acompañado de un plan. Por otro lado, busca ambientar la confianza en las relaciones entre deudor y acreedor. Finalmente, procura refrendar la regla cardinal del sistema jurídico según la cual las obligaciones se contraen para ser cumplidas, en cuyo evento contrario el deudor debe afrontar a sus acreedores y buscar un consenso para modificar los plazos y condiciones.

No basta la regulación de la crisis, es necesario reincorporar al deudor al sistema económico con base en el derecho al olvido con el que cuenta, debido a que la desatención de las obligaciones no es una causa que justifique su exclusión de la sociedad, máxime cuando la contemporaneidad exige su presencia en el sistema económico. Se trata de una situación que no sólo afecta al deudor, sino que, enmarcados dentro de un sistema económico cimentado sobre producción y consumo, los acreedores también se verán perturbados.

Con la reincorporación del deudor al sistema económico se vela no sólo por su interés particular, sino además por la salvaguarda de intereses generales. Sin perjuicio de la importancia de las instituciones enunciadas, dentro del proceso de insolvencia es la figura del descargue la que ocupa el papel estelar como mecanismo de reincorporación del deudor al sistema económico, la cual se analiza a continuación.

Quizá el tema más polémico del nuevo estatuto es la regla prevista para la liquidación patrimonial, según la cual los acreedores no pueden perseguir los bienes que el deudor adquiera con posterioridad y que los saldos insolutos de las obligaciones objeto del procedimiento mutan a obligaciones naturales.

Lo anterior ha sido conocido como descargue, *discharge*, *fresh start*, leyes de punto final, perdón y olvido, un nuevo comienzo o el derecho del deudor de volver a empezar. Desde Aristóteles³⁸, el descargue ha hecho referencia a la posibilidad del deudor de obtener un nuevo comienzo dentro de un mundo donde lo económico se encuentra en relación de interdependencia con lo social y cultural.

³⁷ "La Corte Constitucional, consciente de la necesidad de establecer un término luego del cual la información recolectada debía ser eliminada de las bases de datos, señaló, desde sus inicios, en la Sentencia T-414 de 1992, que el dato personal, en razón a los principios de oportunidad, necesidad y veracidad, está sujeto a 'una vigencia limitada en el tiempo la cual impone a los responsables o administradores

³⁸ "Colocado, pues, Solón al frente de los negocios, libertó al pueblo para el presente y para el futuro con la prohibición de los préstamos sobre la persona, y puso leyes e hizo una cancelación de las deudas privadas (idion) y públicas (dêmosion), que llaman "descarga" (seisachtheia), pues fue como si se hubieran quitado de encima un peso". ARISTÓTELES. *Constitución de Atenas*. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1948.

Actualmente el descargue ha sido incluido dentro del tratamiento concursal de los consumidores³⁹, a propósito de lo cual cabe resaltar que “esta figura, originaria del Derecho estadounidense, ofrece al deudor persona física una segunda oportunidad para iniciar nuevas actividades sin lastres económicos, especialmente cuando la imposibilidad de cumplir con sus acreedores obedece a circunstancias ajenas a su voluntad”⁴⁰. De forma similar, diferentes ordenamientos contemplan la figura. En particular, el sistema francés se funda en la búsqueda de un acuerdo entre acreedores y deudor, interviniendo la autoridad judicial, y ante su fracaso se pueden establecer medidas como el descargue.

A través del descargue se atiende a intereses superiores a aquellos del acreedor, generando una situación macroeconómica positiva al permitir de nuevo el acceso del deudor insolvente al sistema financiero y económico, lo cual, a su vez, evita que se genere un “*efecto dominó*” que podría ocasionarse por el incumplimiento de los créditos de los acreedores del deudor frente a sus terceros acreedores debido al primigenio incumplimiento de éste. Se evita de este modo un descenso en la demanda interna por el descenso del consumo.

La reincorporación al sistema crediticio, al ciclo económico, no debe depender de la actividad del deudor, pues, sin perjuicio de las cargas exigibles a quien tiene la condición de profesional, es claro que debe darse en igual medida a quien no la ostenta. Empero, para dichos efectos sí debe atenderse las consecuencias de su actividad en el sistema económico.

Tres son los engranajes que transmiten la potencia y finalidades del nuevo régimen dentro del sistema económico colombiano: su justificación con base en la crisis del deudor y la necesaria atención al sobreendeudamiento; la naturaleza de los mecanismos que responden a la situación de crisis y; su materialización en la institución del descargue. Articulados estos tres componentes el nuevo régimen pretende reincorporar al deudor al sistema económico; claro está, siempre que se trate de un deudor de buena fe. Consecuentemente, el Código General del Proceso presta atención a la calidad subjetiva del deudor en situación de insolvencia, diferenciándola de aquella de la empresa, lo que genera una mayor protección a intereses superiores al derecho de crédito, como lo son los derechos fundamentales y las obligaciones alimentarias a cargo del deudor. En efecto, si bien la protección de los derechos crediticios de los acreedores es de suma importancia, el ordenamiento no puede desatender al deudor, a la cual le son inherentes una serie de derechos fundamentales.

³⁹ En el derecho norteamericano, el capítulo 7 del Código de Quiebras atinente a la liquidación prevé que el deudor renuncie o sea desposeído de sus bienes y derechos embargables, los cuales llegan a integrar la masa concursal (Estate). Sin embargo, el proceso permite al deudor de buena fe la exoneración de responsabilidad por las deudas, es decir, al final del procedimiento, que puede durar entre 3 y 6 meses, el deudor queda con la posibilidad de empezar de nuevo (fresh start). De manera similar ocurre con el capítulo 13, donde al final el deudor va a obtener el descargue o discharge, pero bajo condición del cumplimiento del plan de pagos.

⁴⁰ ZABALETA DÍAZ, Marta. El concurso del consumidor. Anuario Facultad de Derecho. Universidad de Alcalá III, 2011. p. 311.

En conclusión, todo sistema de insolvencia de persona natural no comerciante debe propender por la reincorporación del deudor al sistema económico, lo cual se materializa a través de los tres pilares mencionados.

En primer lugar, la atención previa a la crisis a través de medidas preventivas tiene como fin la permanencia del deudor dentro del entorno económico en que se encuentra.

En segundo lugar, y ante el fracaso de la primera medida, el ordenamiento prevé una serie de mecanismos o procedimientos cuya naturaleza es recuperatoria. Sólo así pueden generarse efectos positivos en la economía y prevenir colapsos masivos por la gran cantidad de deudores que acceden al proceso.

Finalmente, el descargue hace posible el cumplimiento de los fines establecidos, al permitirle al deudor fracasado, pero de buena fe, tener un nuevo comienzo dentro del mundo económico.

2. ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA LEY DE INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE Y SU RELACIÓN CON LA LEY 1116 DE 2006

2.1 CONCEPTO GENERAL SOBRE INSOLVENCIA

A pesar de que a primera vista el término insolvencia debería resultar de fácil e inmediata comprensión para cualquier persona, y con mayor razón para cualquier profesional de áreas económicas o incluso jurídicas, resulta interesante comprobar que, en el devenir diario de los negocios y procesos de insolvencia, no es así; en su mayoría las personas no comprenden ni la etimología de la palabra, y mucho menos su aplicación práctica dentro de la reglamentación procesal judicial.

Inicialmente se puede entender tal ignorancia por el uso de sinónimos a lo largo de la historia jurídica del país, en donde se ha enmarcado tal condición dentro de criterios tales como el concordato, concepto contenido en el Código de Comercio en su articulado del 1910 al 1936 hasta el año 1989 cuando fueron derogados por el Decreto Extraordinario 350 de 1989, e igualmente en lugar de concordato, rige el proceso de reorganización de la Ley 1116 de 20106.

El término concordato sigue siendo el más usado en los juzgados indistintamente para definir reorganización y liquidación, mismo que a la luz de la normatividad actual pierde todo su sentido. La quiebra, concepto contenido en el Código de Comercio en su artículo 1947 que fue derogado por el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 en donde se le denomina liquidación obligatoria ahora es el llamado proceso de liquidación judicial regulado ahora en la Ley 1116 de 2006. Finalmente, la reestructuración, como término genérico nacido etimológicamente en el mundo empresarial y que se aplica en términos legales dentro del proceso de insolvencia como un todo para la búsqueda de la salvación de la empresa, llamado ahora reorganización empresarial.

Explicado lo anterior queda claro entonces que la definición de insolvencia debe referirse exclusivamente a las dificultades de la persona, comerciante o empresa para cumplir con sus obligaciones económicas. En términos vulgares, escasez o ausencia de dinero para pagar los gastos y las deudas, que contablemente se denomina iliquidez extrema.

De esa forma no debe confundirse el estado de insolvencia con quiebra, pues la primera circunstancia admite una recuperación con sustento en un acuerdo de pagos, que aplica de igual forma para la persona natural no comerciante como para la empresa; y la segunda que se refiere a la liquidación patrimonial de la persona natural no comerciante o la liquidación judicial para la empresa o el comerciante.

2.2 INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE EN EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

Visto lo anterior se llega a los criterios de la insolvencia en general para la persona no comerciante, de acuerdo con lo cual, “con el nuevo régimen de insolvencia, las personas naturales no comerciantes que se cuelguen en sus obligaciones financieras tendrán la oportunidad de renegociar sus deudas con sus acreedores antes de ser embargadas o desalojadas de sus viviendas, tal como ocurre hoy. Esto es, (un salvavidas financiero al que usted tiene derecho si no puede pagar a tiempo o está a punto de quebrar)⁴¹ la salida a la crisis económica de la persona sea cuales fueren las razones o los acreedores a los que les deba.

Esta nueva reglamentación permite a los "morosos" acudir ante un Centro de Conciliación -autorizado por el Ministerio del Interior y de Justicia- para solicitar 60 días hábiles, prorrogables por 30 días más, para negociar con los acreedores sus obligaciones mediante un proceso extrajudicial regulado por un conciliador.

La ley prevé tres alternativas para estos sujetos, a saber, i) la negociación de un acuerdo; ii) la validación de un acuerdo privado y iii) la liquidación patrimonial.

Los procedimientos para el manejo de la insolvencia de la persona natural son de distinta naturaleza: en algunos casos se opta por mecanismos judiciales, en otros administrativos e incluso asistenciales, referidos más a las normas de protección del consumidor o autoridades dispuestas para proteger sus derechos, que a normas de insolvencia.

En este contexto, un primer aspecto a considerar consiste en el deseo del legislador de implementar un instrumento diferente al previsto para el manejo de la insolvencia de la empresa, con lo que se pone de presente el reconocimiento que la insolvencia de la persona natural no comerciante merece un trato distinto que responda a los particulares intereses que se encuentran en juego, por ejemplo, las obligaciones alimentarias a cargo del deudor y los derechos fundamentales que se encuentran en juego.

El régimen soportado en un mecanismo conciliatorio no tiene antecedentes en Colombia, máxime si se toma en cuenta que la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos no ha sido utilizada como herramienta para conseguir acuerdos con acreedores de manera colectiva. ¿Por qué se adoptó la conciliación como eje del mecanismo? La adopción de la conciliación como eje del mecanismo encuentra su justificación en el número reducido de acreedores del deudor persona natural no comerciante, lo cual hace viable este tipo de soluciones.

⁴¹ Finanzas Personales. (2011, septiembre 09). *¿Cómo y cuándo declarase insolvente?* Recuperado de <http://www.finanzaspersonales.com.co/credito/articulo/como-cuando-declararse-insolvente/38051>

De igual manera, la demora en el trámite de los concordatos de personas naturales bajo la vigencia de la ley 222 de 1995 permite justificar la decisión de descartar su continuidad o de contemplar un sistema similar. Es así como la posibilidad del deudor para normalizar el pasivo debe responder a la voluntad de honrar a sus acreedores, acceder a condiciones que le permitan superar el impase temporal por el que se encuentra, más a que a la naturaleza del instrumento.

Se trata principalmente de un espacio de negociación propio de los mecanismos de insolvencia recuperatorios con miras a definir nuevas reglas para la atención del pasivo insatisfecho. Deben ser mecanismos acordes con la situación patrimonial del deudor y que le permitirán en un tiempo determinado normalizarlas y seguir interviniendo en el tráfico económico sin restricciones.

La gran ventaja de este esquema es que todos los acreedores deben acudir obligatoriamente al trámite y escuchar la propuesta de pago del deudor. Además, durante este periodo de conciliación cesan todos los procesos judiciales contra el deudor y se suspende el cobro de cualquier tipo de interés, cuotas de administración y otros cobros (se exceptúan pagos por alimentos). Durante este espacio, los activos productivos no podrán ser embargados mientras se posibilita que el deudor ofrezca todo tipo de intercambio de activos como parte de pago.

Sin embargo, hay que aclarar que no se obliga a las partes a llegar a un acuerdo y que si este no se logra se causarán y cobrarán los intereses de mora y demás cobros que habían sido suspendidos. La insolvencia no es un mecanismo para evitar que sus deudas se hagan efectivas ni para buscar que le condonen sus obligaciones financieras, sino una oportunidad para buscar un arreglo.

Una persona podrá declararse insolvente cuando haya incumplido la cancelación de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por un plazo mayor a 90 días, o cuando cursen en su contra una o más demandas de ejecución o cobro judicial. Además, las obligaciones atrasadas deben representar por lo menos la mitad de la deuda total a cargo del deudor. El acuerdo debe ser aprobado por dos o más acreedores que representen más de la mitad de la deuda y, si se logra dentro de los primeros 60 días hábiles, no se cobrarán los intereses de mora causados durante ese periodo.

¿De qué depende entonces un acuerdo con los acreedores? Como se acaba de establecer, el acuerdo de los acreedores depende de la voluntad del deudor y de la credibilidad que a los acreedores les genere su conducta. Es preciso recordar que la naturaleza conciliatoria no se ve afectada por la posibilidad de que los jueces intervengan en ciertos casos. Puede considerarse que la solución adoptada con la intervención judicial es favorable en la medida que únicamente procede con la existencia de un conflicto entre deudor y acreedores.

No obstante, en aquellos casos en que exista disputa en cuanto a existencia de las acreencias, cuantía y prelación legal, la definición del asunto puede tomar tiempos mayores si se tiene en cuenta la práctica que antecedió en materia de concordatos. Por otro lado, dicha naturaleza se concreta en la posibilidad de celebrar un acuerdo. En este aspecto, llama la atención que la intervención judicial sea esporádica o intermitente y no existe un control integral del mecanismo de la insolvencia, pues el Conciliador debe esperar a que los jueces decidan. En este caso no existe propiamente un Juez de insolvencia como sucede con el trámite de los concordatos o procesos de reorganización: la intervención judicial sólo aplica en los casos dispuestos por la ley y bajo esa consideración es necesario requerir una resolución pronta de los asuntos confiados a la jurisdicción.

Lo realmente importante respecto de la naturaleza conciliatoria de los procedimientos es que el deudor puede normalizar sus relaciones con sus acreedores definiendo unas nuevas reglas de juego para la atención de su pasivo. En efecto, lo valioso es el acuerdo que llegue a celebrarse, más que las etapas previas que deban surtirse para llegar al mismo. Si estamos frente a un deudor organizado, con convicción de llegar a un acuerdo con sus acreedores y comprometido con honrar el derecho de crédito que con el incumplimiento fue desatendido, no tendría por qué haber objeciones máxime si frente a los acreedores existe el consenso que todas las acreencias involucradas en la negociación son ciertas al igual que su cuantía y correcta su prelación legal. Así se podría evitar demoras o actuaciones encaminadas a dilatar injustificadamente la solución a la situación concursal.

Para evitar la proliferación de una cultura del no pago, el deudor no puede haber transferido a terceros sus bienes, dentro de los seis meses anteriores a la aceptación de la solicitud, ni fingir una separación de su cónyuge, pues en este caso se declarará fracasado el acuerdo.

Incluso, está contemplada una sanción penal si se llega a comprobar falsedad o datos incompletos que hagan inducir a error al conciliador o al juez. Además, el deudor no podrá adquirir nuevos créditos ni otorgar garantías a favor de terceros sin el consentimiento de los acreedores. Por último, para evitar el abuso de la figura, un deudor no podrá solicitar el inicio de un nuevo trámite de negociación de deudas sino hasta después de transcurridos cinco años a partir de la fecha de cumplimiento total del acuerdo anterior”.

En aras de ampliar los criterios del resumen que se presenta de lo contenido en el articulado referido se hace remisión al primero (1) de octubre de 2012 cuando comienza a regir en Colombia la Ley de insolvencia de la persona natural no comerciante. De manera general se puede decir que el propósito de estas normas es que el deudor o el garante que se encuentre en cesación de pagos busquen, mediante una negociación, llegar a un acuerdo de cumplimiento de sus obligaciones para con sus acreedores.

2.2.1 Objeto. La regulación contemplada en estos artículos tiene por objeto que la persona natural no comerciante que se encuentre en cesación de pagos pueda:

- a. Negociar sus deudas a través de un acuerdo con sus acreedores para obtener la normalización de sus relaciones crediticias.
- b. Convalidar los acuerdos privados a los que llegue con sus acreedores.
- c. Liquidar su patrimonio.

2.2.2 Requisitos para acogerse al procedimiento de insolvencia.

- a. Que sea persona natural no dedicada al comercio y que no tengan la condición de controlantes de sociedades mercantiles o que formen parte de un grupo de empresas⁴².
- b. Que se encuentre en cesación de pagos: se está en cesación de pagos en los siguientes eventos:
 - Cuando la persona natural, bien sea como deudor o garante, incumpla el pago de dos (2) o más obligaciones a favor de dos (2) o más acreedores por más de noventa (90) días.
 - Cuando contra la persona natural, bien sea como deudor o garante, cursen dos (2) o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva.

En cualquier de estos casos, el valor porcentual de las obligaciones deberá representar no menos del cincuenta (50%) por ciento del pasivo total a su cargo. Para la verificación de esta situación bastará la declaración del deudor la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

2.2.3 Órgano competente para el procedimiento de negociación de deudas y convalidación de acuerdos de la persona natural no comerciante.

- a. Los centros de conciliación del lugar del domicilio del deudor que estén autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho para adelantar este tipo de procedimientos, a través de los conciliadores inscritos en sus listas.

⁴² (CGP) Artículo 532. Ámbito de aplicación.

Los procedimientos contemplados en el presente título sólo serán aplicables a las personas naturales no comerciantes. Las reglas aquí dispuestas no se aplicarán a las personas naturales no comerciantes que tengan la condición de controlantes de sociedades mercantiles o que formen parte de un grupo de empresas, cuya insolvencia se sujetará al régimen previsto en la Ley 1116 de 2006.

- b. Las notarías del lugar de domicilio del deudor, estas lo harán a través de sus notarios y conciliadores inscritos en las listas conformadas para el efecto de acuerdo con el reglamento.

Si en el municipio del domicilio del deudor no existan centros de conciliación autorizados ni notaría, el deudor podrá, a su elección, presentar la solicitud ante cualquier centro de conciliación o notaría que se encuentre en el mismo circuito judicial o círculo notarial, respectivamente.

2.2.4 Costo del proceso de negociación de deudas. Los procedimientos de negociación de deudas y de convalidación de acuerdo serán gratuitos cuando se realicen ante centros de conciliación de consultorios jurídicos de facultades de derecho y de las entidades públicas. Cuando este procedimiento se realice ante notarios o en centros de conciliación privados tendrán cobro, cuyo valor será asumido por la parte solicitante. Si este valor no es cancelado, se entenderá desistida la solicitud.

2.2.5 Forma de realizar el trámite. El interesado deberá realizar un escrito solicitando la negociación de deudas. Este escrito lo podrá presentar directamente o a través de Abogado y se anexarán los siguientes documentos:

- a. Un informe que indique de manera precisa las causas que lo llevaron a la situación de cesación de pagos.
- b. La propuesta para la negociación de deudas, que debe ser clara, expresa y objetiva.
- c. Una relación completa y actualizada de todos los acreedores, en el orden de prelación de créditos que señalan los artículos 2488 y siguientes del Código Civil, indicando nombre, domicilio y dirección de cada uno de ellos, dirección de correo electrónico, cuantía, diferenciando capital e intereses, y naturaleza de los créditos, tasas de interés, documentos en que consten las obligaciones, fecha de otorgamiento del crédito y vencimiento, nombre, domicilio y dirección de la oficina o lugar de habitación de los codeudores, fiadores o avalistas. En caso de no conocer alguna información, el deudor deberá expresarlo.
- d. Una relación completa y detallada de sus bienes, incluidos los que posea en el exterior. Deberán indicarse los valores estimados y los datos necesarios para su identificación, así como la información detallada de los gravámenes, afectaciones y medidas cautelares que pesen sobre ellos y deberá identificarse cuáles de ellos tienen afectación a vivienda familiar y cuáles son objeto de patrimonio de familia inembargable.

- e. Una relación de los procesos judiciales y de cualquier procedimiento o actuación administrativa de carácter patrimonial que adelante el deudor o que curse contra él, indicando el juzgado o la oficina donde están radicados y su estado actual.
- f. Certificación de los ingresos del deudor expedida por su empleador o, en caso de que sea trabajador independiente, una declaración de los mismos, que se entenderá rendida bajo la gravedad de juramento.
- g. Monto al que ascienden los recursos disponibles para el pago de las obligaciones descontados los gastos necesarios para la subsistencia del deudor y de las personas a su cargo si los hubiese, de conservación de los bienes y los gastos del procedimiento.
- h. Información relativa a si tiene o no sociedad conyugal o patrimonial vigente. En el evento en que la haya tenido, deberá aportar copia de la escritura pública o de la sentencia por medio de la cual esta se haya liquidado, o de la sentencia que haya declarado la separación de bienes, si ello ocurrió dentro de los dos (2) años anteriores a la solicitud.
En cualquiera de estos últimos casos, deberá adjuntar la relación de bienes con el valor comercial estimado del que fueron objeto de entrega.
- i. Una discriminación de las obligaciones alimentarias a su cargo, indicando cuantía y beneficiarios.

La información de la solicitud del trámite de negociación de deudas y las declaraciones hechas por el deudor en ese escrito, se entenderán rendidas bajo la gravedad del juramento y en la solicitud deberá incluirse expresamente la manifestación de que no se ha incurrido en omisiones, imprecisiones o errores que impidan conocer su verdadera situación económica y su capacidad de pago.

La relación de acreedores y de bienes deberá hacerse con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior a aquel en que se presente la solicitud. En la propuesta de negociación de deudas, el deudor podrá incluir daciones en pago con bienes propios para extinguir total o parcialmente una o varias de sus obligaciones.

2.2.6 Efectos de la aceptación de la solicitud de negociación de deudas. A partir de la aceptación de la solicitud por parte del conciliador, se producirán los siguientes efectos:

- a. No podrán iniciarse nuevos procesos ejecutivos, de restitución de bienes por mora en el pago de los cánones, o de jurisdicción coactiva contra el deudor y se suspenderán los procesos de este tipo que estuvieren en curso al momento de la aceptación.

- b. No podrá suspenderse la prestación de los servicios públicos domiciliarios en la casa de habitación del deudor por mora en el pago de las obligaciones anteriores a la aceptación de la solicitud. Si hubiere operado la suspensión de los servicios públicos domiciliarios, estos deberán restablecerse y las obligaciones causadas con posterioridad por este concepto serán pagadas como gastos de administración.
- c. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la aceptación del trámite de negociación de deudas el deudor deberá presentar una relación actualizada de sus obligaciones, bienes y procesos judiciales, en la que deberá incluir todas sus acreencias causadas al día inmediatamente anterior a la aceptación, conforme al orden de prelación legal previsto en el Código Civil.
- d. El deudor no podrá solicitar el inicio de otro procedimiento de insolvencia, hasta que se cumplan cinco años contados a partir del momento en que cumpla con lo estipulado en el acuerdo de pago.
- e. Se interrumpirá el término de prescripción y no operará la caducidad de las acciones respecto de los créditos que contra el deudor se hubieren hecho exigibles antes de la iniciación de dicho trámite.
- f. El pago de impuestos prediales, cuotas de administración, servicios públicos y cualquier otra tasa o contribución necesarios para obtener el paz y salvo en la enajenación de inmuebles o cualquier otro bien sujeto a registro, sólo podrá exigirse respecto de aquellas acreencias causadas con posterioridad a la aceptación de la solicitud. Las restantes quedarán sujetas a los términos del acuerdo o a las resultas del procedimiento de liquidación patrimonial.

Se exceptúan los procesos ejecutivos alimentarios que se encuentren en curso al momento de aceptarse la solicitud del procedimiento de negociación de deudas.

2.2.7 Duración del procedimiento de negociación de deudas. El término es de sesenta (60) días, contados a partir de la aceptación de la solicitud. Se podrá prorrogar hasta por treinta (30) días más a solicitud conjunta del deudor y de cualquiera de los acreedores incluidos en la relación definitiva de acreencias. En ningún caso el término podrá sobrepasar los noventa (90) días, pues en ese evento se declarará el fracaso de la negociación y se remitirá la diligencia al Juez civil para que decrete la apertura de la liquidación patrimonial.

2.2.8 ¿Qué se logra con el proceso de negociación de deudas? Llegar a un acuerdo de pago, el cual debe ser cumplido en los términos pactados. Este acuerdo podrá reformarse posteriormente a solicitud del deudor o de un grupo de acreedores que represente no menos de una cuarta parte de los créditos insolutos.

Si el deudor cumple con el acuerdo de pago, podrá solicitar nuevamente un proceso de negociación de deudas a los cinco años contados a partir del cumplimiento total de ese acuerdo.

2.2.9 ¿Qué ocurre si se incumple con el acuerdo de pago? En este caso, el Juez civil declarará el incumplimiento del acuerdo y ordenará al conciliador para que celebre audiencia de reforma del acuerdo. Si al cabo de la audiencia de reforma no se modifica el acuerdo, o si pactada la modificación el deudor incumple nuevamente, el conciliador remitirá el proceso al juez civil de conocimiento para que decrete la apertura del proceso de liquidación patrimonial.

2.2.10 Acuerdos privados. Aquellos acuerdos de pago realizados entre el deudor y sus acreedores que consten por escrito y no fueron sometidos a este procedimiento se denominan acuerdos privados. Estos acuerdos podrán convalidarse ante el centro de conciliación o notario y someterse al procedimiento estipulado para la negociación de deudas.

2.2.11 Liquidación patrimonial. Es un procedimiento mediante el cual el Juez Civil liquida el patrimonio del deudor persona natural no comerciante y profiere sentencia que adjudica a los acreedores esos bienes. Una vez adjudicados los bienes del deudor a sus acreedores, los saldos insolutos de las obligaciones comprendidas por la liquidación mutarán en obligaciones naturales, y producirán los efectos previstos por el artículo 1527 del Código Civil.⁴³

2.3 LEY 1116 DE 2006

2.3.1 ¿Qué es un régimen de insolvencia y para qué sirve? Tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa viable como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de procesos de reorganización y de liquidación judicial.

Este régimen es para aquellas empresas que, siendo viables, se encuentran en crisis transitoria y deben ser sometidas a una reorganización tanto financiera como organizacional, operativa y de competitividad, conducente a solucionar las razones por las cuales se acogieron a este régimen.

⁴³ Gutiérrez, E (2012). *Insolvencia de la persona natural no comerciante*. GYB JURÍDICOS. Recuperado de (<https://gybjuridicos.wordpress.com/2012/10/01/insolvencia-de-la-persona-natural-no-comerciante/>)

El nuevo régimen de insolvencia establece dos procesos a saber reorganización y liquidación obligatoria. Mediante esta Ley 1116 de 2006 se sustituyen los procesos concursales de concordato y liquidación obligatoria regulados por la ley 222 y el proceso de promoción de acuerdos de reestructuración de la ley 550 de 1999.

La reorganización en sentido amplio, es para referirse a los procedimientos cuya finalidad básica sea la de permitir al deudor superar sus dificultades financieras y reanudar o continuar el funcionamiento de sus operaciones comerciales normales, aun cuando en algunos casos pueda incluir la reducción de la capacidad de la empresa, su venta como negocio en marcha a otra empresa y de no lograrlo extinguirse a través de un procedimiento de adjudicación o en caso de incumplimiento del acuerdo celebrado dar lugar a la apertura de un procedimiento de liquidación judicial.

Liquidación judicial prevé en general que ante el juez del concurso se disponga de los bienes del deudor con miras a poner fin a la actividad comercial de la empresa, transformando en dinero los bienes a través de la venta directa o subasta privada y distribuyendo después el producto de la venta o, en caso de no ser posible la venta en todo o en parte, celebrando un acuerdo de adjudicación entre los acreedores aplicando la prelación legal de créditos o en su defecto adjudicándolos a través de providencia judicial.

La liquidación suele concluir con la extinción o desaparición del deudor que sea una entidad jurídica mercantil y la exoneración de todo deudor que sea persona física, comerciante, a menos que dentro del proceso de liquidación judicial se negocie un acuerdo de reorganización que permita que el deudor reanude operaciones.

2.3.2 ¿Quiénes se pueden acoger al régimen de insolvencia?

- a. Personas naturales comerciantes.
- b. Personas jurídicas no excluidas, que realicen negocios permanentes en el territorio nacional de carácter privado o mixto.
- c. Sucursales de sociedades extranjeras.
- d. Patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales, de acuerdo con la reglamentación que expida el gobierno nacional.

2.3.3 ¿Quiénes no se pueden acoger al régimen de insolvencia?

- a. Las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud;
- b. Las Bolsas de Valores y Agropecuarias;
- c. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Lo anterior no incluye a los emisores de valores, sometidos únicamente a control de la referida entidad;
- d. Las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria que desarrollen actividades financieras, de ahorro y crédito;
- e. Las sociedades de capital público, y las empresas industriales y comerciales del estado nacionales y de cualquier nivel territorial;
- f. Las entidades de derecho público, entidades territoriales y descentralizadas.
- g. Las empresas de servicios públicos domiciliarios.
- h. Las personas naturales no comerciantes.
- i. Las demás personas jurídicas que estén sujetas a un régimen especial de recuperación de negocios, liquidación o intervención administrativa para administrar o liquidar.

2.3.4 ¿Ante cuál autoridad se puede solicitar el inicio de un proceso de reorganización o de liquidación judicial?

- a. Ante la Superintendencia de Sociedades en uso de facultades jurisdiccionales: Sociedades comerciales del sector real, Empresas unipersonales, Sucursales de sociedades extranjeras, Personas naturales comerciantes que lo soliciten (a prevención). Haciendo uso de la atribución otorgada por la Ley 1116 de 2007, el gobierno nacional, mediante decreto No. 2179 del 12 de junio de 2007, delegó en las intendencias regionales de la Superintendencia de Sociedades atribuciones necesarias para conocer de estos procesos.
- b. Ante los jueces civiles del circuito del domicilio del deudor: Personas naturales comerciantes que lo soliciten y los demás casos no excluidos del régimen.

2.3.5 ¿Qué requisitos debe cumplir el deudor para iniciar un proceso de reorganización? El inicio de un proceso de reorganización de un deudor supone la existencia de las siguientes situaciones:

- a. Cesación de pagos.
- b. Incapacidad de pago inminente.

2.3.6 Aspectos importantes relacionados con el acuerdo de reorganización.

- a. **Término para celebrarlo:** máximo de 4 meses improrrogables, de acuerdo con lo dispuesto en la providencia de reconocimiento de créditos⁴⁴.
- b. **Aprobación del acuerdo de reorganización:** Debe contar con el voto favorable de un número plural de acreedores que represente por lo menos la mayoría absoluta de los votos admitidos, para lo cual la ley fija unas reglas específicas.
- c. **Confirmación del acuerdo:** se produce luego de que el juez verifica la legalidad del contenido del acuerdo.

2.3.7 ¿Cuáles son las causales de terminación del acuerdo de reorganización?

- a. Por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo.
- b. Si ocurre un evento de incumplimiento no subsanado en audiencia.
- c. Por la no atención oportuna en el pago de las mesadas pensionales o aportes al sistema de seguridad social y demás gastos de administración.

Audiencia de incumplimiento, si el acreedor o deudor denuncia incumplimiento del acuerdo de Reorganización o de los gastos de administración el juez del concurso citará a una audiencia para deliberar sobre la situación; si no es resuelta la situación, el juez declarará terminado el acuerdo y ordenará la apertura del trámite del proceso de liquidación judicial.

⁴⁴ Ley 1429 de 2010. ARTÍCULO 38. El artículo 31 de la Ley 1116 de 2006, quedará así: Artículo 31. *Término para celebrar el acuerdo de reorganización.* En la providencia de reconocimiento de créditos se señalará el plazo de cuatro meses para celebrar el acuerdo de reorganización, sin perjuicio de que las partes puedan celebrarlo en un término inferior. El término de cuatro meses no podrá prorrogarse en ningún caso

2.3.8 Aspectos relacionados con el proceso de liquidación judicial.

a. Causales para iniciar el proceso:

- Incumplimiento del acuerdo de reorganización, fracaso o incumplimiento del concordato o de un acuerdo de reestructuración de los regulados por la Ley 550 de 1999.
- Las causales de liquidación judicial inmediata previstas en la ley.

b. Efectos relevantes producto del inicio de la liquidación judicial:

- La cesación de funciones de los órganos de fiscalización de la persona jurídica,
- La terminación de los contratos de tracto sucesivo, de cumplimiento diferido o de ejecución instantánea, no necesarios para la preservación de los activos, así como los contratos de fiducia mercantil o encargos fiduciarios, celebrados por el deudor en calidad de constituyente, sobre bienes propios y para amparar obligaciones propias o ajenas; salvo por aquellos contratos respecto de los cuales se hubiere obtenido autorización para continuar su ejecución impartido por el juez del concurso.
- La terminación de los contratos de trabajo,
- La finalización de pleno derecho de los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia mercantil celebrados por el deudor, con el fin de garantizar obligaciones propias o ajenas con sus propios bienes.

2.3.9 Terminación. El proceso de liquidación judicial terminará:

- a. Ejecutoriada la providencia de adjudicación de bienes;
- b. Por la celebración de un acuerdo de reorganización.

Acuerdo de reorganización dentro del proceso de liquidación judicial, El liquidador o quienes representen no menos de treinta y cinco por ciento (35%) de los derechos de voto admitidos, podrán proponer la celebración de un acuerdo de reorganización, para lo cual, el juez del concurso convocará a una audiencia. A este acuerdo, le serán aplicables en lo pertinente las reglas previstas en la ley para el acuerdo de reorganización. En caso de incumplimiento del acuerdo de reorganización, será reiniciado el proceso de liquidación judicial⁴⁵.

⁴⁵ Muñoz, J (2013) *Una breve descripción del régimen de Insolvencia de ley 1116 de 2006*. Recuperado de <https://munozmontoya.com/2013/11/07/una-breve-descripcin-del-rgimen-de-insolvencia-de-la-ley-1116-de-2006/>

2.4 ANTECEDENTES DE PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA EN OTROS PAÍSES

En este apartado se desarrolla de forma sucinta el régimen concursal de personas naturales no comerciantes en algunos países latinoamericanos y en España, a fin de visualizar como esta figura se desarrolla en estos países.

2.4.1 España. En España luego de la dispersión normativa frente al régimen de insolvencia contenida de forma dispersa en los códigos de derecho privado, civil y de comercio, lo cual generó traumatismos en la aplicación de esta normatividad, “junto a las clásicas instituciones de la quiebra y del concurso de acreedores, para el tratamiento de la insolvencia de comerciantes y de no comerciantes, respectivamente, se introducen otras, preventivas o preliminares, como la suspensión de pagos, el procedimiento de quita y espera, de presupuestos objetivos pocos claro y por ende límites difusos respecto de aquellas.”

Se expide entonces la Ley 22 de 2003 expedida el 9 de julio, en el régimen Concursal, se denomina por la doctrina “concurso de acreedores” y este régimen se aplica tanto para el deudor no comerciante como al comerciante, sin distinción de persona natural o jurídica. En la legislación española existe una unidad de procedimiento, el cual gira en torno a la insolvencia, entendida como “el estado patrimonial del deudor que no puede cumplir de forma regular sus obligaciones”

El inicio de este procedimiento concursal podrá ser iniciado tanto por el deudor como por sus acreedores, en el primer caso se denomina concurso voluntario en el segundo concurso necesario. El procedimiento de forma indistinta es el siguiente:

- a. Declaración de apertura del proceso.
- b. Lista de acreedores debidamente clasificados.
- c. Inventario de bienes del deudor.
- d. Después de ser aprobado el inventario y la lista de acreedores, se puede optar por las siguientes alternativas:
 - Tramitar un convenio entre el deudor y sus acreedores ordinarios con una quita no superior a un 50% y/o una espera superior a cinco años.
 - acudir a la liquidación dado preferencia la venta de los bienes del deudor.

El juez competente en el caso español es el Juez mercantil sin importar la calidad del deudor (comerciante o no comerciante). En el caso que la solicitud sea realizada por los acreedores el juez citará al deudor a fin de permitirle la oposición, el juez mercantil estudiará la documentación allegada y determinará si existe razón para declarar al deudor en concurso de acreedores. En España, para iniciar este procedimiento se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- a. Memoria de la historia económica y jurídica del deudor
- b. El inventario de bienes y derechos del mismo.
- c. Relación de acreedores en orden alfabético.
- d. Si está obligado a llevar contabilidad deberá presentar las cuentas anuales, el estado de cambios en el patrimonio y los estados financieros intermedios.

Al igual que en la legislación colombiana la liquidación patrimonial es la solicitud alternativa al concurso, el cual tiene un carácter subsidiario y se abre la liquidación cuando se solicite de forma expresa o cuando no prospere la aceptación o cuando el acuerdo o convenio supone la disolución de la sociedad.

Las diferencias con el sistema colombiano se basan en la unificación del régimen concursal como uno solo para personas naturales o jurídicas comerciantes o no, aunado a lo anterior, es un régimen similar en su trámite y comparte el objetivo de solucionar la vida económica de quien se encuentra sobre endeudado. Este trámite se surte directamente ante el juez mercantil, no es un mecanismo alternativo de solución de conflictos como se ha enmarcado en la legislación colombiana.

2.4.2 Argentina. En este hermano país existe la Ley de concursos y quiebras o Ley 24.522. Sancionada el 20 de Julio de 1995. Para personas naturales, sin distinción si son comerciantes o no la legislación Argentina indica dos procedimientos a saber:

- a. **Acuerdo preventivo extrajudicial:** Este acuerdo suscrito por los acreedores y deudor, posee libertad de contenido, es decir, las partes pueden dar al acuerdo el contenido que consideren conveniente a sus intereses y es obligatorio para las partes sin necesidad de la homologación judicial, salvo que se indique lo contrario. Para que este documento, sea homologado por un juez de la República de Argentina se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
 - Un estado de activo y pasivo actualizado a la fecha, del instrumento con indicación precisa de las normas seguidas para su valuación;

- Un listado de acreedores con mención de sus domicilios, monto de los créditos, causas, vencimientos, codeudores, fiadores o terceros obligados y responsables; la certificación del contador debe expresar que no existen otros acreedores registrados y detallar el respaldo contable y documental de su afirmación;
- Un listado de juicios o procesos administrativos en trámite o con condena no cumplida, precisando su radicación;
- Enumerar precisamente los libros de comercio y de otra naturaleza que lleve el deudor, con expresión del último folio utilizado a la fecha del instrumento;
- El monto de capital que representan los acreedores que han firmado el acuerdo, y el porcentaje que representan respecto de la totalidad de los acreedores registrados del deudor.

Ordenada la publicación de los edictos del artículo 74, quedan suspendidas todas las acciones de contenido patrimonial contra el deudor, con las exclusiones dispuestas por el artículo 21.39. Es posible indicar que el acuerdo preventivo extrajudicial es similar a la convalidación de deudas contemplada en la legislación colombiana. El resto de trámite es similar al de insolvencia de persona comerciante, se surte ante juez y no contempla el uso de un conciliador externo al proceso judicial como elemento integral para que se surta el proceso de insolvencia.

2.4.3 Perú. En el año 2002 fue promulgada la ley N° 27809, la cual contiene los lineamientos propios del proceso concursal en el vecino país, este régimen es aplicable tanto a personas naturales como jurídicas sin importar si son comerciantes o no. Para el trámite concursal Perú cuenta con una entidad no judicial denominada La Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI y las Comisiones creadas en virtud de los convenios que se celebren con las instituciones, son competentes para conocer los procedimientos concursales regulados en la Ley, lo cual permite entrever que en estos procedimientos intervienen autoridades no judiciales, como el caso colombiano en el cual intervienen centros de conciliación y notarias.

Esta legislación también muestra un trabajo concomitante entre la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI y el juez de Conocimiento Civil, para acceder al trámite concursal el deudor deberá encontrarse en la siguiente situación. Artículo 24º.- Inicio del procedimiento a solicitud del deudor

24.1 Cualquier deudor podrá solicitar el inicio del Procedimiento Concursal Ordinario siempre que acredite encontrarse en, cuando menos, alguno de los siguientes casos:

- Que más de un tercio del total de sus obligaciones se encuentren vencidas e impagas por un período mayor a treinta (30) días calendario;
- Que tenga pérdidas acumuladas, deducidas las reservas, cuyo importe sea mayor al tercio del capital social pagado.

24.2 En caso de que la solicitud sea presentada por el deudor, éste expresará su petición de llevar a cabo una reestructuración patrimonial o uno de disolución y liquidación, de ser el caso, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Para una reestructuración patrimonial, el deudor deberá acreditar, mediante un informe suscrito por su representante legal y por contador público colegiado, que sus pérdidas acumuladas, deducidas las reservas, no superan al total de su capital social pagado.
El deudor también especificará los mecanismos y requerimientos necesarios para hacer viable su reflotamiento, y presentará una proyección preliminar de sus resultados y flujo de caja por un período de dos (2) años.
- De no encontrarse en el supuesto del inciso a) precedente, el deudor sólo podrá solicitar su disolución y liquidación, la que se declarará con la resolución que declara la situación de concurso del deudor. Si el deudor solicita su acogimiento al Procedimiento Concursal Ordinario al amparo del literal a) del numeral precedente, pero tiene pérdidas acumuladas, deducidas reservas, superiores al total de su capital social, sólo podrá plantear su disolución y liquidación.

24.3 La solicitud que se sustente en una situación distinta de las señaladas en el párrafo precedente será declarada improcedente.

24.4 Las personas naturales, sociedades conyugales o sucesiones indivisas deberán cumplir, además, al menos uno de los siguientes supuestos:

- Que más del 50% de sus ingresos se deriven del ejercicio de una actividad económica desarrollada directamente y en nombre propio por los mencionados sujetos.
- Que más de las dos terceras partes de sus obligaciones se hayan originado en la actividad empresarial desarrollada por los mencionados sujetos y/o por terceras personas, respecto de las cuales aquellos hayan asumido el deber de pago de las mismas. Se incluye para estos efectos, las indemnizaciones y reparaciones por responsabilidad civil generadas con el ejercicio de la referida actividad.

Los aspectos subjetivos para acceder a un proceso concursal son mucho más amplios que en la legislación colombiana, mientras que la legislación peruana indica una cesación de pagos de 30 días, para Colombia se exige una cesación de pagos prolongada de mínimo noventa días., en caso de la persona natural se exigen dos supuestos, inexistentes en el caso colombiano:

- Que más del 50% de sus ingresos se deriven del ejercicio de una actividad económica desarrollada directamente y en nombre propio por los mencionados sujetos.
- Que más de las dos terceras partes de sus obligaciones se hayan originado en la actividad empresarial desarrollada por los mencionados sujetos y/o por terceras personas, respecto de las cuales aquellos hayan asumido el deber de pago de las mismas.

Se incluye para estos efectos, las indemnizaciones y reparaciones por responsabilidad civil generadas con el ejercicio de la referida actividad. Esto puede deberse a que el régimen concursal se encuentra unificado tanto para personas naturales y/o comerciantes.

A diferencia del caso colombiano este trámite para persona natural también podrá ser iniciado por sus acreedores, figura que no se encuentra prevista en el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante colombiano.

2.4.5 Ecuador. El régimen de insolvencia de persona natural no comerciante se encuentra descrito en el Código Civil del mencionado país. A continuación, se presenta el análisis de la norma realizado por Ana María Larrea jurista ecuatoriana. Se establece la insolvencia en casos específicos, y se denomina quiebra en caso de comerciantes. Se dispone la clasificación de insolvencia en fortuita, culpable y fraudulenta en caso de cesión de bienes. Se concreta la tramitación o actuación general del concurso de acreedores, que por general se establece en el auto inicial de calificación (acumulación de autos, prohibición de salida del país, interdicción de administrar bienes...) Se verifica el trámite breve de la cesión de bienes, en donde el deudor realiza un informe de los activos y pasivos con motivos de por qué realiza la cesión.

Establece las causas de concurso de acreedores, de entre ellas:

- Cuando, requerido el deudor con el mandamiento de ejecución, no pague ni dimita bienes;

- Cuando los bienes dimitidos sean litigiosos, o no estén poseídos por el deudor, o estén situados fuera de la República, o consistan en créditos no escritos, o contra personas de insolvencia notoria;
- Cuando los bienes dimitidos sean insuficientes para el pago, según el avalúo practicado en el mismo juicio, o según las posturas hechas al tiempo de la subasta. Para apreciar la insuficiencia de los bienes, se deducirá el importe de los gravámenes a que estuviesen sujetos, a menos que se hubieren constituido, para caucionar el procedimiento.

Se regula los créditos con mayoría de las dos terceras partes, respetando la prelación de créditos del código civil y las adicionales de este parágrafo, si se está de acuerdo o no con la prelación el juez emite resolución sobre dichos asuntos. Luego de la calificación de créditos el juez convocará para que los acreedores se reúnan a fin de realizar el convenio, en dicha junta se ponen de acuerdo y cada acreedor tiene voto excepción de los privilegiados a menos que renuncien a su derecho de privilegio, el fallido debe estar presente personalmente, si no solicita nueva audiencia o que no exista convenio. Causales de nulidad del convenio celebrado fraudulentamente con uno o más acreedores. Tales acreedores se ven obligados a restituir lo recibido como consecuencia de convenio fraudulento.

La solicitud de rehabilitación se publica por la prensa y admite oposición de terceros cuyas deudas no se hayan extinguido. Deudor debe demostrar solvencia. Los deudores culpables o fraudulentos solo pueden rehabilitarse luego de cumplida su condena, transcurridos 5 años y pagado todas sus obligaciones; además de haber observado conducta “irreprensible”.

Cabe la rehabilitación luego de muerte la persona natural, y en caso de abandono al impulso del proceso por diez años o más, caso en el que se entiende que no habría que demostrar pago de obligaciones⁴⁶.

Es un proceso similar al regulado por el Código General de procesos colombiano, no obstante, el trámite se surte ante el juez de la república y no ante un conciliador como lo contempla el caso colombiano.

⁴⁶ Larrea, A. Análisis crítico del concurso de acreedores en el Ecuador y reflexiones para su reforma. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ecuador 2013. P. 39

3. ALTERNATIVAS MÁS EFECTIVAS PARA LLENAR LOS VACÍOS EN LA APLICACIÓN DE LA INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE

3.1 ANÁLISIS COMPARATIVO

Una vez explicada y entendida la insolvencia, indistintamente al tipo de deudor al que se haga referencia, (Persona natural no comerciante, comerciante o persona jurídica) resulta normal que se quiera entender por qué se crean estatutos diferentes para cada caso y cómo tales aplicaciones pueden resultar complementarias unas de otras en la búsqueda del cumplimiento de su objetivo de acuerdo con su origen finalístico en armonía con los principios que les rigen.

Partiendo del hecho de que es apenas natural que el procedimiento establecido en la Ley 1116 de 2006 resulta mucho más detallado y extenso, en el entendido que se debe dejar abierta la posibilidad a un número ilimitado de acreedores y unos valores de activos mucho más elevados con sus diversas complicaciones, en número de artículos establecidos para su desarrollo e igualmente unos términos mucho más amplios para su ejecución en comparación con el de la persona natural no comerciante puede suponerse, de entrada, que esta ley complementaría la segunda, en el evento de ser necesario.

De los lineamientos estructurales de los dos estatutos se comprende hasta aquí que, dado el hilo conductor de los antecedentes legislativos y el análisis hecho a tales antecedentes, se puede establecer una ruta a seguir de donde se desprendan los criterios aplicables para los dos casos en estudio.

3.1.1 De las partes en los procesos de insolvencia, deudor y acreedor. Del análisis de ambas figuras jurídicas se encuentran aspectos o elementos que le son comunes tales como: i) la identificación de las partes de una obligación, esto es, *acreedor y deudor* que resultan ser en sí mismas el presupuesto inicial para entabrar una controversia de tipo económico patrimonial que deba ser regulada por las leyes para la organización y auto regulación del mercado.

Es necesario resaltar que son partes de la controversia absolutamente independientes y autónomos dentro del proceso; vale aclarar que ninguno de los mismos necesita abogado para hacerse representar en ninguna de sus instancias. Tal circunstancia tiene explicación práctica que se ratifica en lo legal. Para el deudor, el hecho de que se encuentra en dificultades económicas, el pago de un apoderado le significa una erogación que hace más pesada su difícil situación.

Para el acreedor la posibilidad de declinar en buena parte sus intereses a favor de un arreglo en condiciones ventajosas para el deudor, buscando con ello la recuperación del capital invertido o acreditado a favor del primero, pero que en todo caso le permite salvar la mayor cantidad o monto de su acreencia, por lo que contar con un apoderado le resta a ese monto esperado. Lo dicho se da en los dos casos, de negociación de deudas o de reorganización y en la liquidación patrimonial o judicial.

Quien debe velar, entonces, por los intereses legítimos de las partes (deudor y acreedor) es el operador de insolvencia en la negociación de deudas, y el juez del concurso tanto para la reorganización, como para la liquidación. El conciliador, el promotor y el liquidador, como auxiliares de la justicia son facilitadores de los distintos procesos de tal forma que se adelanten con eficiencia, eficacia y celeridad.

Lo anterior, permite concluir que la base estructural de la insolvencia impone la necesidad primigenia de contar con estos dos extremos, puesto que, tanto las empresas, como las personas naturales no comerciantes bien pueden hacer parte de cualquiera de las dos figuras ya señaladas, bien sea como acreedor o bien sea como deudor.

De la negociación de deudas a través de acuerdo y de la convalidación de acuerdos, conocerán los centros de conciliación del lugar del domicilio del deudor, expresamente autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho para adelantar este tipo de procedimientos.

En caso de cumplirse los presupuestos para la Liquidación de patrimonial, conocerá de ésta el Juez Civil Municipal en única instancia.

Hasta aquí en relación con los parámetros de la Ley 1116 de 2006, lo estipulado para personas jurídicas, se asimila en todo lo que tiene que ver con los supuestos de admisión, excepto en lo que tiene que ver con la presentación de la información financiera que para el caso de una sociedad o un comerciante, en razón a su obligación de llevar contabilidad, supone mayor rigurosidad en los datos que soportan los estados financieros de acuerdo al tipo de empresa o actividad comercial a la que se dedique y que determina sus obligaciones tributarias e información legal para su funcionamiento; aquí empiezan a aparecer elementos que los distancian y que finalmente pueden convertirse en un obstáculo insalvable.

Inicialmente el operador de insolvencia para las personas jurídicas cobijadas por la Ley 1116 de 2006 es la Superintendencia de Sociedades, y los jueces civiles del circuito⁴⁷, para los casos que les corresponda, ante los cuales se puede solicitar o

⁴⁷ ARTÍCULO 6o. COMPETENCIA. Conocerán del proceso de insolvencia, como jueces del concurso: La Superintendencia de Sociedades, en uso de facultades jurisdiccionales, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3o del artículo 116 de la Constitución Política, en el caso de todas las sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras y,

adelantar el proceso de reorganización; que podrá hacerse directamente o a través de abogado, que en todo caso será gratuito. Para el caso de la persona natural no comerciante opera la misma facultad en cuanto a la solicitud de admisión a trámite de negociación de deudas, puede hacerse directamente, sin necesidad de abogado; que también es gratuito cuando se adelanta en centros de conciliación de consultorios jurídicos de las facultades de derecho⁴⁸ pero a diferencia de las primeras cuando se adelanta en un centro de conciliación privado o una notaría se exige el pago de un valor establecido en una tabla creada⁴⁹ para el efecto según decreto 2677 de 2012.

Respecto de la gratuidad para la persona natural no comerciante, que en atención a su condición económica en general debería ser por lo menos en las mismas condiciones de los comerciantes y empresas puesto que sus montos de activos de capital son mucho menores, se observa una inequidad muy grande al revisar los centros de conciliación debidamente autorizados por el Ministerio de Justicia y el Derecho se observa que solo existen con esa condición una en Bogotá, una en Cali, Una en Medellín, una en Pereira y una en Cúcuta, ni Neiva, ni el resto de ciudades del país cuenta con centros gratuitos para acceder a tal régimen, amén de los escasos que resultan los existentes para el nivel población en donde operan y en la mayoría de otras ciudades no están dadas las condiciones para que los consultorios jurídicos las lleven a cabo y menos en el resto de entidades estatales que no les interesa llevarlas a cabo.

E ahí un obstáculo grande para la persona natural insolvente, pues precisamente ese es su problema, la falta de liquidez para cumplir con sus obligaciones financieras lo que constituye una circunstancia subvalorada por el legislador y que dificulta entonces en alta medida el acceso al beneficio, no solo de la persona insolvente, sino también a la sociedad que ve truncada la posibilidad de una recuperación del mismo mercado de compradores o consumidores como se señaló en las consideraciones sobre impacto económico planteadas en capítulo precedente.

a prevención, tratándose de deudores personas naturales comerciantes. El Juez Civil del Circuito del domicilio principal del deudor, en los demás casos, no excluidos del proceso.

⁴⁸ CGP Artículo 535. Gratuidad. Los procedimientos de negociación de deudas y de convalidación de acuerdo ante centros de conciliación de consultorios jurídicos de facultades de derecho y de las entidades públicas serán gratuitos. Los notarios y los centros de conciliación privados podrán cobrar por sus servicios.

Las expensas que se causen dentro de dichos procedimientos deberán ser asumidas por la parte solicitante, de conformidad con lo previsto en las reglas generales del presente código.

En el evento en que las expensas no sean canceladas, se entenderá desistida la solicitud.

Son expensas causadas en dichos procedimientos, las relacionadas con comunicaciones, remisión de expedientes y demás gastos secretariales.

⁴⁹ ARTÍCULO 27. TARIFAS MÁXIMAS APLICABLES A LAS NOTARÍAS. La Superintendencia de Notariado y Registro determinará mediante resolución las tarifas a cobrar por los notarios para conocer de los Procedimientos de Insolvencia, dentro de los topes máximos fijados por el artículo anterior. Para la fijación de los montos, tendrá en cuenta que estas deben constituir una equitativa retribución del servicio y que no pueden gravar en exceso a quienes acceden a los Procedimientos de Insolvencia. Dichas tarifas serán revisadas anualmente.

En conclusión, el procedimiento observa como principio orientador la gratuidad, el cual aplica si el trámite se pretende adelantar frente a los Centros de Conciliación de los Consultorios Jurídicos de universidades; empero, para las otras entidades validadas reconocidas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, esto es, las Notarías de los diferentes Círculos y Centros Privados de Conciliación, tienen tarifas establecidas por la contraprestación del servicio; si dichas expensas del trámite no son debidamente canceladas, la solicitud será en este caso desestimada. Siguiendo con el análisis, entonces, se dictan unas reglas técnicas dirigidas al encargado de darle trámite a dicha solicitud, es decir, al conciliador capacitado en la materia; que no necesariamente es abogado, cuando cumple el requisito de hacer parte del listado de auxiliares de la Superintendencia de Sociedades; dichas reglas giran sobre las facultades y atribuciones que éste ostentará durante todo el procedimiento de negociación de deudas, algunas de ellas son: i) Citar al deudor y a sus acreedores de conformidad con lo dispuesto en este título. ii) Ilustrar al deudor y a los acreedores sobre el objeto, alcance y límites del procedimiento de negociación de deudas y del acuerdo de pagos iii) Actuar como conciliador en el curso del procedimiento de insolvencia. iv) Solicitar la información que considere necesaria para la adecuada orientación del procedimiento de negociación de deudas, v) Motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con base en la propuesta de negociación presentada por el deudor, entre otras.

3.1.2 De las condiciones para acceder al proceso de insolvencia. Otro elemento común en los estatutos en consideración es: ii) Serían además de la cesación de pagos, que a su vez comparten el mismo término para su acaecimiento, además de un término común para ambas de más de noventa (90) días de incumplimiento, de dos (2) o más obligaciones a favor de dos (2) o más acreedores, contraídas en desarrollo de su actividad o tenga por lo menos dos (2) demandas de ejecución presentadas por dos (2) o más acreedores para el pago de obligaciones. Condiciones básicas prácticas como indicadores de insolvencia que representan las verdaderas dificultades probadas de su incapacidad para responder a los acreedores; que muestra además cómo la regulación sobre la insolvencia de persona natural no comerciante se adentra cada vez más a las raíces de la legislación sobre insolvencia empresarial y que, por lo tanto, se tendría que tener en cuenta para llenar los vacíos existentes en ese estatuto, como se podrá demostrar más adelante.

Dados los presupuestos mencionados, que denotan una correlación directa con información financiera obtenida en estados de contabilidad, a la que no están obligadas las personas naturales no comerciantes; pero que dependen en su caso de la que lleva el sistema económico y que obliga a encuadrar la insolvencia de estas en el mismo escenario comercial o empresarial propiamente dicho; pues es con entidades financieras, en su mayoría, con quienes se comprometen las personas para la adquisición de créditos.

Exige la norma (art. 539), que para la presentación de la solicitud de trámite de negociación de deudas, se cumplan ciertos requisitos tales como: i) informe argumentando los hechos que llevaron al deudor a ese estado de insolvencia, ii) sus alternativas razonadas para llegar a un eventual acuerdo de sus deudas, incluso cómo podría pagar con los propios bienes para extinguir las obligaciones adquiridas y en atención a la naturaleza del procedimiento en la persona natural se debe verificar el estado civil, ya que de esta circunstancia se va a desprender si existen obligaciones alimentarias a cargo del deudor y qué bienes en el eventual caso se consideran del haber conyugal o patrimonial de hecho. Circunstancia, esta última, por obvias razones, no contemplada en la reorganización empresarial de los comerciantes; el resto recibe un tratamiento similar, respecto de los requisitos que debe tener la solicitud de *reorganización empresarial* prevista en la Ley 1116 de 2006 de que trata la insolvencia empresarial.

3.1.3 Del acuerdo de pagos. Otro punto de coincidencia se refiere a: iii) la negociación o alternativas para saldar las acreencias; que en términos generales es la misma posibilidad que tendría uno y otro deudor; diferenciado en la forma en que se llega a ese objetivo y los términos para ser aprobado. En el caso de la persona natural no comerciante el conciliador tiene veinte (20) días para fijar la fecha de audiencia de negociación de deudas, la cual debe darse en sesenta (60) días, desde la fecha de aceptación de la solicitud, pudiendo ser prorrogada por treinta (30) días más. A diferencia de la reorganización empresarial en donde los plazos son mucho más amplios, comenzando por el plazo para la presentación de créditos que es desde veinte (20) días y hasta dos (2) meses, término luego del cual se pondrán en traslado por otros diez (10) días el estado de inventarios del deudor y de cinco (5) días para la graduación de créditos y derechos de voto, otros tres (3) días para el traslado de objeciones y diez (10) para la conciliación de estas últimas. Una vez reconocidos los créditos el juez fijará un plazo máximo de cuatro meses para presentar el acuerdo de reorganización a que lleguen las partes, que no podrá ser prorrogado⁵⁰.

Esa diferencia estaría dada debido a la supuesta complejidad de información en cuanto a activos y acreedores del deudor empresarial. Esa misma situación se presenta en algunos casos en la persona natural no comerciante, no obstante, su calidad, puesto que algunos de ellos cuentan con activos de muy alto valor o en un gran número e igualmente un conjunto de pasivos de una complejidad incluso mayor que la de muchos comerciantes o sociedades.

⁵⁰Ley 1429 de 2010. ARTÍCULO 38. El artículo 31 de la Ley 1116 de 2006, quedará así:

Artículo 31. *Término para celebrar el acuerdo de reorganización.* En la providencia de reconocimiento de créditos se señalará el plazo de cuatro meses para celebrar el acuerdo de reorganización, sin perjuicio de que las partes puedan celebrarlo en un término inferior. El término de cuatro meses no podrá prorrogarse en ningún caso.

Repasando entonces se encuentra que, (Art 542), dentro de los cinco (5) días siguientes a la aceptación del cargo, el conciliador verificará si la solicitud cumple con los requisitos legales. De ser así, iniciarán la primera etapa referente a la *negociación de las deudas*. Para ello se fijará fecha para audiencia de negociación dentro de los veinte (20) días siguientes a la aceptación de la solicitud; como el legislador fue consciente que dicho trámite puede tornarse algo complejo, estableció que la negociación de deudas sería de sesenta (60) días, contados a partir de la aceptación de la solicitud; más puede darse que de forma conjunta el deudor y cualquiera de los acreedores incluidos en la relación definitiva de acreencias, soliciten que éste término pueda ser prorrogado por treinta (30) días más.

Dentro de este apartado se plantean las posibilidades de pago a las que se pueda llegar en el acuerdo en el que se puede hacer cualquier convenio estipulado en la ley colombiana tales como dación en pago, quitas o cualquier otro arreglo a que haya lugar, para los dos casos en análisis. Ya en cuanto al plazo que pueda darse para el pago de la totalidad de las deudas encontramos algunas diferencias; en el caso de la persona natural no comerciante, según lo estipulado en el artículo 553 de la Ley 1564 de 2012, no podrá preverse un plazo superior a cinco (5) años para el pago completo de los pasivos. Que sin embargo deja la posibilidad de ampliarlo si lo aprueba más del sesenta por ciento (60%) de los créditos o si originalmente la obligación tenía un término superior. Cosa que en la reorganización empresarial no se menciona, dejando abierta la posibilidad para que se presente cualquier fórmula de pago. Lo anterior indica que en cualquiera de los dos casos de estudio se puede acordar un plazo, determinado solo por la voluntad de las partes, incluyendo condiciones, periodos de gracia, etc., en consonancia con el título XIV del Código Civil que estipula los modos de extinguirse las obligaciones.

Un aspecto importante entre los dos procedimientos se observa al revisar el art. 546, que señala que, si existen personas con mejor derecho, tal es el caso de los menores; en donde si se adelantaren *procesos ejecutivos alimentarios* que se encuentren en curso al momento de aceptarse la solicitud del procedimiento de negociación de deudas, continuarán conforme al procedimiento previsto en la ley, sin que sea procedente decretar su suspensión ni el levantamiento de las medidas cautelares. Misma circunstancia considerada en el artículo 77 de la Ley 1116 de 2006, en el que adicionalmente se señala que tales procesos alimentarios deben ser incluidos en la calificación y graduación de los créditos.

Igual procede en lo referente a los gastos de administración, o gastos necesarios para la subsistencia del deudor y de las personas que éste tenga a su cargo, así como de las obligaciones que el deudor debe seguir atendiendo o sufragando durante el procedimiento y posterior etapa de negociación, que van a ser tenidos en cuenta para ser pagados con un carácter de preferencia y no entraran a ser parte del acuerdo de pago que se determine para las demás acreencias. Que resulta siendo igual para el caso de la reorganización empresarial.

La parte final de esta etapa resulta ser la audiencia de negociación de deudas, que estará sujeta a las reglas contempladas en la norma en su art. 550, es decir, a unos parámetros bajo los cuales se celebrara la misma, esto se refiere a: i) El conciliador pondrá en conocimiento de los acreedores la relación detallada de las acreencias y les preguntará si están de acuerdo con la existencia, naturaleza y cuantía, si tienen dudas o discrepancias con relación a lo expuesto por el deudor, de no presentarse objeción alguna, se determinará como la relación definitiva de acreencias ii) De existir oposiciones, diferencias, el conciliador propiciará fórmulas de arreglo dado su conocimiento en el tema de insolvencia, y podrá si es caso suspender la audiencia. iii) Si reanudada la audiencia, las objeciones no fueron conciliadas, el conciliador procederá en la forma descrita en los artículos 551 y 552. iv) Si no hay objeciones o estas fueron conciliadas, habrá lugar a considerar la propuesta del deudor. v) El conciliador solicitará al deudor que haga una exposición de la propuesta de pago. vi) El conciliador preguntará al deudor y a los acreedores acerca de la propuesta y se podrán dar contrapropuestas o alternativas de arreglo. vii) De la audiencia se levantará un acta que será suscrita por el conciliador y el deudor. Tal acuerdo es de obligatorio cumplimiento en todas sus partes. En caso contrario, es decir de encontrar probado el incumplimiento, en el mismo auto que lo declare, el juez ordenará que se devuelvan las diligencias al conciliador, para que se proceda la viabilidad de estudiar la reforma del acuerdo. De no modificarse el acuerdo o el deudor llegase a incumplir nuevamente lo acordado, se tendrá que dar apertura del proceso de liquidación patrimonial.

En la parte final de este apartado, en la misma Ley 1564 de 2012 se introduce el Capítulo III que habla de la convalidación del acuerdo privado en el que ese deudor podrá solicitar que se convalide el acuerdo privado que hubiere celebrado con un número plural de acreedores que le implicará a éste ceñirse a unas reglas especiales de procedimiento. El artículo 84 de la Ley 1116 contempla igual posibilidad con condiciones similares. En suma, todo acuerdo convalidado, será oponible y obligará a todos los acreedores del deudor. Como en términos generales la aprobación del acuerdo y sus partes son muy similares en los dos casos de análisis, en el evento de que, transcurrido el término previsto, no se celebra el acuerdo de pago el conciliador declarará el *fracaso* de la negociación e inmediatamente remitirá las diligencias al juez civil de conocimiento para que decrete la apertura del proceso de liquidación patrimonial. Que es igual para la reorganización en donde el mismo juez asume el proceso de liquidación judicial.

3.1.4 De la liquidación. Finalmente queda, en esta etapa de análisis el cuarto elemento a definir: iv) La liquidación, que puede ser a petición de parte (*acreedor o deudor*) o de manera conjunta. Aquí vale la pena hacer énfasis en un criterio que a la luz de los deudores no es totalmente claro y por lo tanto se presta para interpretaciones equivocadas en la aplicación de las normas en aras de salvar el patrimonio o el negocio en general; y es el hecho de que, en cualquiera de los casos, en el evento de ser admitido a un proceso de negociación de deudas o de

reorganización, si no se llega a un acuerdo de pagos o si este se incumple, sea cual fuere su condición o plazo, da lugar a la liquidación. Debe quedar claro que el hecho de acceder a esa posibilidad de salvamento, de igual forma le obliga inevitablemente a estar sujeto a la liquidación, que en todo caso como se explicó en el análisis económico es también es una forma ordenada de hacer un descargue y una solución para las partes.

En todos estos presupuestos se vería abocado a ésta última circunstancia que pese a ser común, no siempre se produce, puesto que el desarrollo del proceso de la insolvencia supone etapas que evitan el llegar al último escenario, cuál es la liquidación de un patrimonio. En relación con esta etapa, la cual según la práctica conocida desde que se implementó la insolvencia de persona natural no comerciante, ha resultado ser la de mayores dificultades, vacíos y equivocadas interpretaciones por parte de los jueces encargados de los mismos se le va a darle un mayor énfasis en su tratamiento y análisis de tal forma que pueda hacerse la mayor claridad posible, con los argumentos fácticos y legales más objetivos que orienten con suficiencia su mejor aplicación.

Pues bien, de este extremo considerado verdaderamente grave, que sin embargo más bien resulta en muchos casos de un alivio para el deudor en cuanto se hace el denominado descargue⁵¹, que le permite resolver en un solo procedimiento todas las obligaciones a su cargo, previendo además la liberación de ejecuciones futuras por saldos insolutos, incluyendo el buen nombre relacionado con los reportes en las centrales de riesgo, entre otros importantes beneficios, se verifican más diferencias que similitudes. En este estado de cosas, para la persona natural no comerciante, en cuanto se hayan superado las etapas de negociación de deudas, , llegado al punto en donde o fracase la negociación, o se declare la nulidad del acuerdo o se dé su incumplimiento da lugar a la apertura de la liquidación patrimonial; situación apenas similar para la reorganización empresarial en donde los presupuestos son muchos más complejos, como se puede evidenciar en el resumen del primer título de este trabajo, pero igual concluye en la misma circunstancia fáctica.

Pues bien, en aras de darle mayor claridad al siguiente análisis comparativo, veamos los siguientes casos prácticos de procesos de insolvencia de persona natural no comerciante adelantados a instancias de la Cámara de Comercio de Neiva, en la etapa de negociación de deudas, y de liquidación patrimonial en juzgados civiles de la jurisdicción del municipio de Neiva.

⁵¹ Rodríguez Espitia, Juan José (2013). *Crisis, procedimientos y descargue: Los cimientos del nuevo régimen de insolvencia de persona natural no comerciante*. Recuperado de <https://letrujil.files.wordpress.com/2013/09/15juan-jose-rodriguez.pdf>. .. Quizá el tema más polémico del nuevo estatuto es la regla prevista para la liquidación patrimonial, según la cual los acreedores no pueden perseguir los bienes que el deudor adquiera con posterioridad y que los saldos insolutos de las obligaciones objeto del procedimiento mutan a obligaciones naturales. Lo anterior ha sido conocido como descargue, *discharge*, *fresh start*, leyes de punto final, perdón y olvido, un nuevo comienzo o el derecho del deudor de volver a empezar. Desde Aristóteles³³, el descargue ha hecho referencia a la posibilidad del deudor de obtener un nuevo comienzo dentro de un mundo donde lo económico se encuentra en relación de interdependencia con lo social y cultural.

Ahora bien, adentrados en la situación real de la liquidación patrimonial de la persona natural no comerciante que denota muchos vacíos de aplicación por parte de los jueces, ahondado ya el detrimento del deudor al no poder llegar a un acuerdo de pagos, en detrimento de los acreedores por la insolvencia en donde se espera un camino mucho más expedito que le permita recuperar la mayor cantidad posible de sus intereses en el menor tiempo posible, cosa que no se da. Se verá entonces el procedimiento establecido en el Capítulo IV, del Título IV del CGP en cuanto decreta esa liquidación la cual se sustenta en los elementos precedentes mencionados que llevan a la aplicación del artículo 564 de la providencia de apertura, del mismo estatuto.

En tal providencia el juez debe disponer inicialmente el nombramiento de un liquidador y la fijación de sus honorarios provisionales. De este numeral se desprenden varias circunstancias que merecen su análisis y es donde se encuentran las verdaderas diferencias y deficiencias, más que vacíos, en comparación con la Ley 1116 de 2006.

- a. **Sobre el nombramiento del liquidador:** En primer lugar, respecto del nombramiento del auxiliar de la justicia que debe actuar como liquidador, en la norma no se señala con precisión el criterio que debe tenerse en cuenta para su nombramiento, seguramente porque el operador judicial recibe el proceso ya en la etapa final, ya surtida la opción de la negociación de deudas que es donde se hace referencia al Decreto 2677 de 2012 reglamentario de la insolvencia de persona natural no comerciante. Se comete muy frecuentemente el error de designar el auxiliar de la justicia del listado oficial del Consejo Superior de la Judicatura aplicando bajo esa lógica el criterio de designación allí señalado (Artículo 48 del CGP), en donde se deben incluir tres nombres, a la espera de que alguno de ellos concurra a notificarse, designando al primero que lo haga dentro de los cinco días siguientes a la comunicación, que si ninguno asistiere deberá reemplazar tal listado aplicando la misma regla.

Y si pasan esos cinco días, y nombran a otros tres y tampoco concurren, y así sucesivamente. Pues es muy claro que difícilmente alguno de ellos va a concurrir puesto que no están preparados para ejercer ese oficio en razón a que no han recibido la instrucción respectiva o tampoco tienen la experiencia requerida. E aquí un grave error en la aplicación de la norma. Tal designación aparece estipulada en el artículo 47 del Decreto 2677 de 2012, indicando que los jueces nombrarán los liquidadores de la lista clase C elaborada por la Superintendencia de Sociedades, aleatoriamente, sin que medie una terna o cualquier otra circunstancia que haga más lento y engorroso el proceso en contravía de la celeridad pretendida en la aplicación de la justicia, que además es, por sobradas razones, uno de los principios que rigen la insolvencia.

Ahora, en los casos en que efectivamente se aplique lo señalado por la Ley para el nombramiento del liquidador, se encuentra con otro obstáculo en muchos casos insalvable, y es que para designar al auxiliar de la justicia del listado oficial de la Supersociedades no se tiene en cuenta el domicilio de éste, aún a pesar de la jurisdicción a la cual corresponda, nombrando profesionales que se ubican en Bogotá para procesos de Neiva, Pitalito o hasta Mocoa o Nariño, por ejemplo, sin considerar que ello implica desplazamientos que generan gastos que no se compadecen con los bajos honorarios a percibir y mucho menos acordes a la capacidad dada en términos del monto de los activos de la liquidación que terminan siendo la fuente de pago de los gastos de administración, lo que finalmente genera que nunca se notifiquen o acepten tales nombramientos; haciendo igualmente lento el mismo comienzo del proceso.

Si esto ocurre en ciudades intermedias, como las mencionadas, en donde se podría solucionar buscando auxiliares con domicilios en la misma ciudad, o ciudades cercanas como Ibagué para el caso de Neiva, o de la misma Neiva para procesos de otros municipios cercanos. Algo similar ocurre con los procesos de insolvencia de comerciantes adelantados en los Juzgados del Circuito que se niegan a acudir al criterio apenas lógico de seleccionar con base en la mayor cercanía con el domicilio del mismo. Cosa diferente a como es manejado por la Superintendencia de Sociedades que se remite al Decreto 2130 de 2015 en el que se señala como criterios, entre otros, la jurisdicción en la cual se encuentre inscrito el auxiliar en relación directa con la jurisdicción de la entidad que se encuentre en trámite de reorganización o liquidación.

- b. **Sobre la fijación de honorarios:** Viene ahora la segunda parte del artículo en estudio cual es “*la fijación de honorarios provisionales*” determinados por la misma ley como “*los honorarios respectivos constituyen una equitativa retribución del servicio...*”, artículo 47 del CGP que como ya se dijo resultan muy bajos y por tanto poco atractivos para auxiliares de la justicia inscritos en el listado de la Supersociedades, y que además representan otro obstáculo a superar. La fijación de tales honorarios provisionales no tiene una regla para ser establecidos, no se señala bajo qué criterio o con base en qué sustentaría el monto de esos honorarios, contrario a lo establecido en la norma referida que detalla, de acuerdo a la categoría de la entidad (según el monto de sus activos), Sección 7, Honorarios y Gastos, artículo 2.2.2.11.7.4, del Decreto 2130 de 2015, que fija la remuneración del liquidador en los procesos bajo la Ley 1116 de 2006. Pues bien, para el caso en estudio, queda al libre albedrío del juez de la liquidación que en su mayoría pretende fijarlos de acuerdo con las tarifas del Consejo de la Judicatura que tampoco es coherente con el tipo de proceso que se está adelantando. Todo ello desconociendo, igualmente, el concepto mismo de “*provisionales*”, que claramente constituye una remisión a la norma con la que se está haciendo la comparación que tiene en cuenta la realidad práctica del ejercicio del auxiliar de la justicia puesto que el decreto mencionado se establece un pago inicial de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes en

la fecha de vencimiento del término para la presentación del proyecto de calificación de créditos de la entidad en liquidación, ajustando un pago del 40% del monto total de los honorarios en la fecha de ejecutoria de la providencia mediante la cual se aprueba la calificación y graduación de créditos; que es el momento cuando se fijan los honorarios definitivos a reconocer por su labor al liquidador.

Esta modalidad, lógicamente, ajustada al tipo de proceso adelantado en relación directa con el monto de activos objeto de liquidación; pero que, guardadas las proporciones, refleja la equitativa retribución de los servicios del auxiliar, lo mismo que la cobertura de los gastos materiales necesarios para el desarrollo de gestión. En ese orden de ideas se espera entonces que en alguna etapa del proceso se fijen unos honorarios definitivos y se determine su forma y medio de pago. Cosa que finalmente, en los casos conocidos, no se aplica en debida forma y por ende genera otro malestar en el auxiliar de la justicia que ve mermada esa justa retribución por su trabajo y que podría también impactar negativamente en la finalización más eficiente del proceso.

- c. **Respecto de las coincidencias:** Cumplido ese primer paso, y en el cumplimiento del propósito de continuar con el análisis comparativo, vienen los numerales siguientes del mismo artículo 564 del CGP, que van desde el 2 hasta el 5, en concordancia directa con el artículo 48, numerales 1 al 9 de la Ley 1116 que son en esencia los mismos pasos del procedimiento, en donde además se puede observar a simple vista que se tomaron los mismos criterios de esta última ley puesto que en la mayoría de ellos se usan los mismos términos, en otros los mismos textos, para expresar lo pretendido en cuanto a asuntos como notificaciones, acumulación de procesos, igualdad entre acreedores, la integración y destinación exclusiva de todos los bienes y derechos del deudor que componen la masa para pagar las obligaciones con los acreedores, la terminación de los contratos de trabajo, la preferencia de las normas sobre liquidación sobre cualquier otra que le sea contraria, entre otros.

Sin embargo, a pesar de tantas coincidencias, se encuentran algunas diferencias que se convierten en falencias en la liquidación patrimonial de la persona natural no comerciante, en comparación con la liquidación judicial del comerciante. En aras de darle una explicación coherente a la circunstancia mencionada se puede suponer que como la verdadera intención de la norma es la de conseguir un acuerdo de pagos en la negociación de deudas se dejó un tanto corto el procedimiento de la liquidación patrimonial. Otra tesis podría ser la de que, al suponer que los bienes de la persona son mucho menores, exigiría un procedimiento más corto y eventualmente más sencillo, que realmente no lo es; o que, se espera que en su aplicación al presentarse vacíos se llenen con la norma que, además de que sirvió de base para la redacción de la otra, contiene todos los pasos necesarios para su feliz cumplimiento.

Dentro de los efectos que produce la apertura de la liquidación judicial se encuentran eso sí diferencias bastante lógicas por cuanto la persona natural no reúne las condiciones para consideraciones como cesación de órganos sociales y de fiscalización, separación de los administradores, notificación al ministerio del trabajo, la finalización de encargos fiduciarios, entre otras que no merecen un análisis mayor por su lógica. Pues bien, dicho lo anterior, se analizará qué vacíos se encuentran y cómo sería posible llenarlos usando los artículos contenidos en el aparte sobre liquidación judicial de la Ley 1116 de 2006.

- d. **Sobre el inventario de bienes y los avalúos:** El numeral 3 del artículo 564 del CGP indica que se ordenará al liquidador para que actualice el inventario valorado de los bienes del deudor, para lo cual deberá tomar como base la relación de bienes presentada en la negociación de deudas y el avalúo se hará según lo dispuesto en el artículo 444 del mismo estatuto. Aquí también se subvalora la importancia de los bienes del insolvente persona natural no comerciante puesto que en la gran mayoría de los veces la valoración de inventarios bajo ese criterio no consulta la realidad de los bienes en el comercio por exceso o por defecto permitiendo el aprovechamiento a favor de unos pocos de los bienes del patrimonio del deudor en detrimento de los acreedores no privilegiados. Luego, el artículo 567 amplía el criterio indicando que se debe hacer el traslado de estos para las posibles observaciones a los mismos con la posibilidad de allegar un avalúo diferente, sin explicar de qué manera o bajo qué criterios debe ser presentado ese nuevo avalúo.

Además de lo limitado que resulta presentarlos sustentado en el artículo 444 mencionado, que solo habla de los bienes inmuebles y vehículos automotores, sin considerar otro tipo de bienes diferentes que eventualmente pueden resultar en un monto muy representativo para el interés de los acreedores, o bien porque pueden correr el riesgo de perderse si no se dispone su realización de manera inmediata, o bien porque exigen un tratamiento especial en cuanto a su valoración por su exclusividad, etc., todo ello posibilita o que sean sobrevalorados o subvalorados, todo en detrimento de la eficiencia y eficacia en el desarrollo del proceso y de una mejor cobertura a todos los acreedores, y hasta para el mismo deudor que podría beneficiarse si quedaran remanentes a su favor.

En la Ley 1116 de 2006 el tema de los inventarios es tratado inicialmente en el numeral 9 del artículo 48, en concordancia con el 564 del CGP, señalándose que el liquidador debe presentar el inventario de activos que serán avaluados por expertos designados por la Supersociedades, según lo establecido en el Decreto 1730 de 2009; luego en el artículo 53 se menciona la actualización de los créditos reconocidos y el inventario de bienes del acuerdo de reorganización. A diferencia de lo considerado en el CGP, en este caso el Decreto 1730 de 2009 reglamenta los artículos 48, 57, 81 y 84 de la Ley 1116 de 2006 sobre inventarios, avalúos, peritos y evaluadores, con lo que entrega un

direccionamiento explícito, claro y amplio sobre este asunto que con sobradas razones deber ser tratado con el mayor cuidado. Vacío de la liquidación patrimonial en el CGP, procedimiento que debería tener en cuenta los parámetros mencionados ampliando los criterios en cuanto a avalúos y forma de aprovechar los bienes de la mejor manera posible en aras de mejorar la masa y de darle mayor claridad, certeza y eficacia a este ítem puesto que de allí se desprenden los verdaderos intereses, tanto de los acreedores, como del deudor y el impacto que socialmente genera la mejor resolución del proceso.

- e. **Sobre las medidas cautelares:** En este tema la reglamentación sobre insolvencia de persona natural no comerciante resulta muy limitada, y podría decirse que cercenada en un fondo de tanta importancia, pues ni en la etapa de negociación de deudas, ni en la liquidación patrimonial se hace mención a este hecho que a todas luces resulta necesario por cuanto se deben salvaguardar los bienes de la masa de posibles intervenciones de terceros, o del mismo deudor que podría enajenarlos, en desmedro de la protección de los créditos reduciendo con ello las posibilidades de recuperación de estos para los acreedores.

Tal vez la única parte en la que se hace alusión a la protección de esos bienes, pero sin señalar cómo hacerlo, es en el numeral 2 del artículo 565 indicando que los bienes del deudor se deben destinar exclusivamente a pagar obligaciones anteriores al inicio del procedimiento de liquidación, lo que podría tomarse como base para ordenar la fijación de medidas cautelares sobre los bienes afectos al proceso; pero que incluso podrían afectar (dependiendo de la interpretación del juez) el pago de los mismo gastos de administración si se aplicara taxativamente “...a pagar exclusivamente obligaciones anteriores al inicio del proceso...”. La pregunta que cualquiera debe hacerse es, ¿cómo se garantiza que los bienes de la masa estén a disposición del juez de la liquidación para disponer de ellos en cuanto se vaya desarrollando el proceso y de esa manera se puedan honrar las obligaciones pasadas, presentes y futuras como consecuencia del mismo? Este que es un tema de normal práctica en todo tipo de procesos ejecutivos y por lo tanto ampliamente tratado en la normatividad civil y comercial, no se pone de presente con la claridad y la contundencia que merece. Es apenas lógico que no merece mayor argumentación al respecto.

A diferencia de todo lo anterior, en el artículo 54 de la Ley 1116 de 2006 se decreta mantener las medidas que se hayan practicado sobre los bienes del deudor, sea cual fuere la causa, y además se ordena inscribir los bienes a órdenes del juez concursal, incluyendo la entrega inmediata de éstos al liquidador para que actúe como secuestre, disponga de la mejor manera de ellos y les dé el tratamiento adecuado en la medida de las necesidades del proceso buscando su conservación y aprovechamiento. Del estudio de la mencionada disposición se observa que la finalidad de las medidas cautelares es proteger la universalidad objetiva y subjetiva e igualdad que debe darse en todo proceso de insolvencia, toda vez que el patrimonio del deudor constituye la prenda

general de todos los acreedores, y por lo tanto, la capacidad dispositiva del deudor debe restringirse a aquellos actos necesarios para su subsistencia, en el caso de persona natural, o de funcionamiento, para los otros casos, y que no comprometan su patrimonio. Así mismo, determina de una parte que, si los acreedores pierden el derecho de ejecución individual o separada y el proceso de insolvencia es el único escenario previsto para hacer valer sus créditos, no tiene razón de ser acudir a otros mecanismos para obtener el pago de estos, y de otra, que el principio de igualdad hace relación a que todas las obligaciones deberán ser atendidas dentro del proceso en las mismas condiciones para todos los acreedores. He aquí otra gran diferencia que obliga a la reflexión en cuanto que debería tenerse en cuenta también para éste caso esta ley para aplicar en la liquidación patrimonial de la persona natural no comerciante por las razones anotadas.

- f. **Sobre la adjudicación:** El artículo 570 del CGP, remitido por el 568 que habla de la providencia de resolución de objeciones, aprobación de inventarios y avalúos, y citación a audiencia, que es la de adjudicación teniendo como hecho previo la presentación del proyecto de adjudicación por parte del liquidador; dice que el juez oír las alegaciones que las partes tengan respecto del proyecto de adjudicación presentado por el liquidador procediendo a proferir la providencia respectiva. Tal adjudicación contiene los mismos criterios establecidos en el artículo 58 de la Ley 1116 de 2006 en cuanto a las reglas para adjudicación de bienes no enajenados de que habla esta última norma haciendo referencia a “...de bienes no enajenados...” en atención a que el artículo 57 se refiere a la enajenación de activos y plazo para presentar el acuerdo de adjudicación. En este apartado, a diferencia de lo reglado en el CGP sobre este tema, se fija un plazo de dos (2) meses desde la firmeza de la calificación y graduación de créditos y el inventario de bienes del deudor para enajenar los activos inventariados por un valor no inferior al del avalúo, de ahí la importancia de un avalúo idóneo por el bien de las partes. La venta puede hacerse en forma directa o mediante subasta privada. Es la posibilidad de venta la gran diferencia entre los dos estatutos en esta parte del procedimiento.

La razón tiene que ver esencialmente con la posibilidad de hacer el pago de los créditos reconocidos a los acreedores de la forma más eficiente posible puesto que, como es evidente, el hecho de disponer de efectivo facilita ese pago en cuanto a la subdivisión que se da en la gran mayoría de los casos entre acreedores de mayor a menor calidad o privilegio. Además del hecho de que, la misma norma en el numeral 5 del artículo 58 ordena la adjudicación de bienes en común y proindiviso en la proporción que corresponda a cada uno generando de por sí las consabidas dificultades para la disposición de esos bienes, por lo que el hecho de disponer de efectivo es a todas luces, y por lógica general, la manera precisa de tal pago previniendo con ello conflictos posteriores. Si se adelanta la adjudicación sin disponer de dinero en efectivo tendrán que pagarse gastos como servicios públicos, registros en entidades en donde se obligue

hacerlo, así sea en mínimas cantidades, labores de conservación de bienes, etc., con bienes en común y proindiviso que lo que causan es mayores gravámenes a los ya sufridos por los acreedores y ahora a terceros no involucrados en la liquidación. Lo adecuado es que, en esta etapa procedimental final, el juez del proceso autorice la enajenación de los bienes de la masa de los que se disponga de tal forma que se permita con el dinero en efectivo, basado en un buen avalúo de ellos, la facilidad de los pagos al momento de determinar esas obligaciones, junto con las acreencias graduadas y reconocidas objeto de la adjudicación.

- g. **Sobre los gastos de administración:** Adicional a los argumentos esgrimidos respecto de disponer de efectivo para el pago de acreencias, que además resulta coherente, concordante y conducente en relación con la intención de la liquidación judicial planteada en términos de que lo que se persigue es la liquidación pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento de los bienes del deudor; aprovechamiento que se traduce en la realización de tales bienes que implica por lo tanto su enajenación; se encuentran los diferentes pagos a hacer, dentro de los que también están los honorarios del liquidador ya analizados en la primera parte de este capítulo. Antes de la misma adjudicación deben tenerse en cuenta las obligaciones causadas con posterioridad a la fecha de inicio del proceso de insolvencia, definidos como gastos de administración, que en cuanto a la disposición legal para su cumplimiento se debe atener a que todos aquellos generados con posterioridad al inicio del proceso, sea de reorganización, negociación de deudas o liquidación se debe pagar en la medida en que se van causando⁵², según se desprende del artículo 71 de la Ley 1116 de 2006, circunstancia que tampoco es tenida en cuenta dentro del procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante.

Del estudio de la norma en mención, se desprende que los gastos de administración surgidos durante un proceso de reorganización o liquidación judicial deben pagarse inmediatamente y a medida que se vayan causando. Como se puede apreciar, la aludida disposición protege los derechos del acreedor contratante al disponer que las obligaciones causadas a partir de la iniciación del proceso de reorganización deberán cumplirse de preferencia en los términos y condiciones inicialmente estipulados, y su incumplimiento, tal como lo dispone el inciso segundo del artículo 21 ibídem, da lugar a la terminación del contrato respectivo, sin que pueda alegarse que el deudor está en proceso de reorganización o liquidación judicial, según el caso. Luego, los gastos de administración a que alude el artículo 71 ibídem, hace referencia a todas aquellas obligaciones que se causen como consecuencia de la apertura de un proceso de insolvencia, llámese acuerdo de reorganización o liquidación judicial, tales como los honorarios del promotor o del liquidador, los gastos

⁵² ARTÍCULO 71. OBLIGACIONES POSTERIORES AL INICIO DEL PROCESO DE INSOLVENCIA. “Ver Notas del Editor” Las obligaciones causadas con posterioridad a la fecha de inicio del proceso de insolvencia son gastos de administración y tendrán preferencia en su pago sobre aquel objeto del acuerdo de reorganización o del proceso de liquidación judicial, según sea el caso...

necesarios para el mantenimiento de la empresa en funcionamiento o la conservación de activos que conforman el patrimonio a liquidar, las deudas contraídas por el representante legal de la insolvencia, las obligaciones por servicios públicos o derivadas de contratos de tracto sucesivo. En resumen, se tiene que uno de los efectos de los procesos concursales es la división de las obligaciones a cargo del deudor en dos categorías: i) las causadas antes de la fecha de inicio del proceso de insolvencia respectivo, las cuales quedarán sujetas a las resultas de éste, es decir, que solamente se pueden hacer valer dentro del mismo y sus titulares pierden el derecho de ejecución individual o separada; y ii) las originadas con posterioridad a la fecha de apertura del proceso, las cuales tienen el carácter de gastos de administración, y por ende, deben pagarse en la forma prevista en el artículo 71 ya citado⁵³.

Este último es otro elemento de suma importancia desconocido en la liquidación patrimonial del CGP y que en consecuencia debería, ya que no lo tiene contemplado en su articulado, ser llenado con la norma en mención puesto que se acomoda a las verdaderas necesidades del procedimiento. Como el estatuto en cuestión adolece de este procedimiento obliga el pago de los gastos de administración mediante la figura de la adjudicación de bienes, en la mayoría de los casos en común y proindiviso con los acreedores graduados y calificados, recibiendo por su puesto bienes diferentes a dinero (En los casos en que no se dispone del él, que son la mayoría). La pregunta es ¿cómo se libra un bien adjudicado para el pleno goce de este por parte de los adjudicatarios, si la norma no prevé la disposición de efectivo para el pago de servicios públicos, impuestos y otros gastos propios de los bienes en general? Esos bienes quedan en la parte correspondiente también a nombre de entidades públicas como la Dian, los municipios, oficinas de registro y hasta notarías cuando haya la necesidad.

- h. **Sobre la terminación del proceso:** Ya como parte final dentro del propósito intrínseco contemplado para el desarrollo del presente trabajo las etapas subsiguientes y los trámites procedimentales son coincidentes entre las dos normas en análisis. Temas como que el proceso terminará una vez quede ejecutoriada la providencia de adjudicación, en el caso del comerciante, y una vez se aprueben las cuentas finales presentadas por el liquidador en el caso de la persona natural.

Es igual en cambio para los dos casos el tratamiento que se le debe dar a las acciones revocatorias y la simulación, entre otras que se encuentran taxativamente señaladas en las dos normas. Con la excepción del reconocimiento de los honorarios definitivos para el liquidador que en el caso del CGP, como ya se expresó en páginas anteriores, no se establece ni su

⁵³ Accounter. (2010) *Pago de gastos de administración y situación jurídica de los contratos fiducia en garantía dentro de un proceso de insolvencia – Ley 1116 de 2006*. Oficio 220-034801 – 08/Junio Recuperado de <http://www.accounter.co/normatividad/oficios/pago-de-gastos-de-administracion-y-situacion-juridica-de-los-contratos-fiducia-en-garantia-dentro-de-un-proceso-de-insolvencia-ley-1116-de-2006.html>

reconocimiento, y mucho menos, la forma de su pago; a diferencia de la Ley 1116 de 2006 en la que se establece que se pagará el 40% restante y disponible para ese objeto, una vez aprobada la rendición final de cuentas, que es definitivamente la última providencia proferida en el proceso, que tiene como acción final la autorización para que sea pagado el saldo final de honorarios al liquidador.

Para una mejor comprensión de los argumentos expuestos, y en aras de dar mayor claridad a la teoría planteada se presenta el primer caso práctico adelantado en un juzgado de Colombia.

Resumen actuaciones proceso rad.2015-00265 insolvencia persona natural no comerciante:

La persona natural no comerciante, con sustento en el artículo 531 de la Ley 1564 de 2012, solicita el día 16 de enero de 2015, ante la Cámara de Comercio de Neiva, ser admitida a proceso de negociación de deudas a través de un acuerdo con sus acreedores para obtener la normalización de sus relaciones crediticias. En esa instancia se adelantan las diligencias correspondientes llegando a la audiencia de negociación de deudas realizada el 11 de marzo de 2015, en la cual fracasa la propuesta de pagos presentada por la deudora y por lo cual el expediente es enviado al juez civil de conocimiento.

El proceso le corresponde por reparto al juzgado Primero Civil Municipal de Neiva, radicado el día 18 de marzo de 2015. El juzgado admite la demanda y profiere auto de apertura de liquidación patrimonial solo hasta el día 19 de junio de 2015, es decir, exactamente tres meses después de ser radicado en el juzgado respectivo.

Otro vacío de la norma que no establece un término razonable que permita prevenir situaciones como deterioro de activos, aumento de intereses en las obligaciones, incertidumbre en los acreedores, indefinición en la situación jurídica de los activos de los que se pudiere disponer para adicionar a la masa liquidatoria, entre otros que en definitiva exigirían corregir este ítem. (Anexo A)

En el mismo auto de apertura de la liquidación patrimonial, como lo establece el artículo 564 del CGP, se designa un liquidador fijando un monto provisional de honorarios, de los que no se señala los criterios tenidos en cuenta para su fijación, por lo que al parecer se calculan al libre e indeterminado criterio del juez permitiendo con ello fisuras que en determinado momento pudieren posibilitar una manipulación de cualquiera de las partes interesadas de los valores de honorarios a reconocer y pagar. (Anexo B)

Posesionado de su encargo el día 1 de julio de 2015, el liquidador adelanta las diligencias correspondientes y en cumplimiento de lo estipulado en el numeral 3 del artículo 564 del CGP presenta el inventario valorado que debe hacerse según lo señalado en el mismo artículo que indica que se debe remitir al artículo 444 en sus numerales 4 y 5, que dice:

...tratándose de bienes inmuebles el valor será el del avalúo catastral del predio incrementado en un cincuenta por ciento (50%), salvo que quien lo aporte considere que no es idóneo para establecer su precio real. En este evento, con el avalúo catastral deberá presentarse un dictamen obtenido en la forma indicada en el numeral 1.

Y para los vehículos automotores el valor será:

...el fijado oficialmente para calcular el impuesto de rodamiento, sin perjuicio del derecho otorgado en el numeral anterior. En tal caso también podrá acompañarse como avalúo el precio que figure en publicación especializada, adjuntando una copia informal de la página respectiva.

Situación está que resulta incoherente con la realidad comercial de los bienes obrantes en la masa liquidatoria puesto que nunca se compadecen con el valor al que pudieran ser vendidos, o en el caso de presentarse un avalúo adelantado por un perito debidamente autorizado, sin mencionar a cargo de quién estaría el costo de tal gestión. Que supondría una carga más en cabeza de los bienes de la masa como gasto de administración que es.

Ahora bien, para este proceso en específico se presenta una situación aún más singular, primero en la valoración de los bienes comienza a tener dificultades en la aplicación de la misma norma puesto que en el expediente obran tres valores diferentes y no se precisa frente a las diferentes posibilidades de avalúos existentes la forma de determinar el valor de éstos; por ello la señora juez ordena fijar un valor determinado por un perito contratado especialmente para este proceso; el cual finalmente es pagado con cargo a los bienes de la masa.

En medio de las dudas generadas solo hasta el 3 de agosto de 2015 se profiere un auto de trámite de tal forma que se impulse el proceso, entre esta fecha y el 25 de agosto se reciben varias peticiones que quedan pendientes de ser resueltas puesto que encontrándose en este punto, por decisión de la judicatura, se ordena remitir el proceso al Juzgado Primero de Descongestión Civil Municipal de Neiva, en donde se desconoce el procedimiento adecuado al caso y entonces requieren al liquidador para que dé razón de lo acontecido hasta ese momento, no pueden resolver inmediatamente las peticiones hechas dentro del mismo y citan fecha para proferir providencia de resolución de resolución de objeciones que no se puede llevar a cabo en razón a que no se dispone de los

inventarios por encontrarse pendiente resolver peticiones presentadas por los acreedores.

Entre decidir qué ordenar para normalizar el proceso y cumplir con las etapas correspondientes al mismo se pasa el mes de diciembre de 2015, pasa a enero de 2016 y se acaba el presupuesto para el funcionamiento de los juzgados de descongestión causando con ello que los procesos recibidos sean devueltos a sus juzgados de origen, situación que para el caso que nos ocupa se da efectivamente solo hasta el mes de marzo de 2016, comenzando la juez a tomar decisiones solo hasta el mes de abril.

Seguramente la situación ocurrida no tiene nada que ver con el normal desarrollo de este tipo de procedimiento, pero debe ser mencionada puesto que con ello se verifican todas las dificultades a las que se ven abocados y por lo cual deben tenerse en cuenta frente a cualquier análisis al respecto. Entre solicitudes, diligencias y órdenes de avalúos y registros se recibe del apoderado oficio donde solicita la exclusión y se adjudique el 50% de los derechos de propiedad de un bien inmueble y del parqueadero que figuran a nombre de la deudora, considerándolos como garantía real, y sustentados en la Ley 1676 de 2013 que se refiere a la promoción del crédito mediante normas de garantías mobiliarias, la cual en su reglamentación incluye las garantías hipotecarias.

En fecha 31 de octubre de 2016 finamente se profiere la providencia de resolución de objeciones, aprobación de inventarios y citación a audiencia de adjudicación. En tal diligencia se le reconoce al acreedor hipotecario la exclusión del bien inmueble solicitado con sustento en lo señalado en el artículo 52 de la Ley 1676 de 2013, e igualmente solicita al liquidador la elaboración del proyecto de adjudicación, aclarando que la fijación de sus honorarios definitivos se hará una vez culminada su gestión.

Respecto de ésta última parte, en lo que tiene que ver con los honorarios definitivos, adicional a la crítica hecha a la fijación inicial de éstos en cuanto son provisionales pero que no se sujetan a ninguna forma o sustento práctico, se hace imposible que se pueda presentar un proyecto de adjudicación propiamente dicho sin tener determinado el monto total de honorarios a ser reconocidos como justa contraprestación de su labor como auxiliar de la justicia puesto que éstos salen de la misma masa del activo del deudor y por lo tanto afectan la distribución que se haga de los mismos en el reconocimiento de créditos y en el pago de los gastos de administración a que haya lugar.

De igual forma, como se puede ver, la norma no contempla la posibilidad de la realización de los bienes afectos al proceso liquidatorio, es decir su venta para hacer efectivos esos valores y de esa manera conseguir un pago mucho más expedito y a todas luces eficiente. Frente a tal circunstancia el liquidador hace la solicitud de autorización de venta de los bienes, misma que es negada por la

juez del concurso. Lo que obliga a adjudicar los bienes en común y proindiviso y con lo cual se deja un problema a resolver por parte de los acreedores al recibir una o varias partes de bienes que pueden ser muebles o inmuebles y que adolecen de avalúos acordes a la realidad comercial; que además deben ser saneados o administrados mientras se logra un acuerdo o venta de los mismos entre los adjudicatarios que en la mayoría de los casos corresponden a entidades como la DIAN, el Municipio, entidades bancarias, cooperativas, etc., frente a las cuales se hace muy difícil, tanto la venta de los bienes recibidos como su coadministración.

Finalmente, como quedó establecido en el auto proferido el 31 de octubre de 2016, se adelanta audiencia de adjudicación el día 6 de diciembre de 2016. En esta la señora Juez resuelve adjudicar a prorrata de acuerdo con lo señalado en la norma, pero incurre en un error. Al reconocer la exclusión del bien inmueble se tiene en cuenta que su valor no alcanza a cubrir el valor reconocido a ser pagado a favor del acreedor, siendo éste un crédito hipotecario, que lo hace preferente, y el saldo se lo reconoce como de segunda categoría. Tal decisión es contraria a lo señalado en el artículo 2510 del código civil que establece que los créditos preferentes que no se hayan cubierto en su totalidad, de acuerdo a la graduación respectiva, pasarán por déficit a quinta clase, en donde concurrirán a prorrata.

La audiencia es recurrida por el Liquidador solicitando su nulidad y por tanto la correspondiente corrección de los yerros cometidos y la sujeción a los lineamientos establecidos en normas más acordes a lo necesitado, el recurso es desestimado por la juez del concurso. De esa forma se da por terminado en forma definitiva el proceso de liquidación patrimonial de persona natural no comerciante adelantado en el juzgado primero civil municipal de Neiva, Huila.

Como corolario de lo expuesto se presenta un resumen general de las más importantes y representativas sentencias de las altas cortes relacionadas directamente con el tema en estudio y que nos permiten soportar con mayor énfasis y seguridad lo referido en las conclusiones presentadas dejando de por sí un estandarte judicial inobjetable. Corte Constitucional, Sentencia C-699 del 2007, Magistrado Ponente, Rodrigo Escobar Gil, (Declara exequible el artículo 126 de la Ley 1116 de 2006. El numeral 2° del fallo establece: “Segundo. - Exhortar al Congreso de la República para que dentro del ámbito de su potestad de configuración legislativa expida un régimen universal para personas naturales no comerciantes”).

Corte Constitucional Sentencia T-079 de 2010, Magistrado Ponente, Luis Ernesto Vargas Silva, (Se refiere a los principios más importantes que deben regir a los procesos concursales, entre los cuales señala el de universalidad e igualdad entre acreedores, también conocido como par conditio omnium creditorum.

De acuerdo con el principio de universalidad, todos los bienes del deudor conforman una masa patrimonial que se constituye en prenda general de garantía de los acreedores; así mismo, los acreedores establecen una comunidad de pérdidas, lo que significa que sus créditos serán cancelados a prorrata, o en proporción a las posibilidades económicas, una vez realizada la venta de los bienes del deudor.)

Corte Constitucional, Sentencia C-685 del 2011, Magistrado Ponente, Humberto Antonio Sierra Porto, (Declara inexecutable la Ley 1380 de 2010 que regulaba el proceso de recuperación de la persona natural no comerciante por vicios de forma).

Corte Constitucional, Sentencia C-527 de 2013, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio, (Define que los procesos concursales tienen como finalidad conciliar los intereses de los deudores, los acreedores y la sociedad en su conjunto, en el evento de insolvencia del deudor, con la finalidad de proteger el crédito, bien sea mediante fórmulas de recuperación del deudor, que le permitan pagar ordenadamente, o a través de la liquidación de su patrimonio.)

Corte Constitucional, Sentencia T-734 de 2014, Magistrada Sustanciadora (e) Martha Victoria Sáchica Méndez, (Define de acuerdo con la Ley 1116 de 2006 el procedimiento a seguir en proceso de liquidación judicial con las siguientes etapas: i) Apertura del proceso de liquidación judicial, ii) Nombramiento de un liquidador, iii) Fijación de un aviso por parte del juez del concurso, iv) Presentación de créditos, v) Proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, vi) Enajenación de activos y vii) Terminación de proceso liquidatorio.)

4. CONCLUSIONES

Nociones como acreedor, deudor, bienes, insolvencia, intereses, acciones judiciales, cesación de pago, liquidación patrimonial, negociaciones, acuerdos, derecho sobre los bienes del deudor entre otros; poseen desde su connotación hasta su denotación elementos aplicables tanto a la insolvencia empresarial como también a la insolvencia de persona natural no comerciante, y de la misma forma se ven insertos en cada uno de los pasos del proceso, generando una similitud que al final resultan convirtiéndose en la repetición de la acción y gestión en los dos casos.

Lo anterior nos permite determinar cuatro elementos dentro de los dos procesos, que resumen y justifican nuestras principales conclusiones, tales son como sigue:

- En cuanto a los supuestos de insolvencia en los dos procesos se ajustan de manera similar los criterios a tener en cuenta para acudir a la figura de negociación de deudas en el caso de la persona natural no comerciante que se encuentra inserto en el artículo 538 de la Ley 1564 de 2012, supuestos denominados de admisibilidad en la Ley 1116 de 2006 bajo el título de reorganización, señalados en el artículo 9°, que son exactamente los mismos como se pudo corroborar el análisis comparativo en su numeral 3.1.2, concluyendo que siendo el primer análisis a hacer por parte del insolvente, tanto como su primer paso, resultan iguales en la práctica.
- En cuanto a las clases de acuerdos propuestas para los no comerciantes, se evidencia dos clases de validación de los acuerdos; el primero siguiendo las reglas establecidas del artículo 531 y siguientes, y el segundo, según lo ya reseñado, el deudor y los acreedores podrían convalidar un acuerdo privado de negociación de deudas (artículo 562 CGP) que deberá hacerse reconocer ante autoridad notarial o judicial. Cosa exactamente igual a las opciones establecidas en la Ley 1116, que permite así mismo la validación de acuerdos extrajudiciales de reorganización que han cumplido con los requisitos del procedimiento normal de la misma ley.
- En cuanto al operador competente, como se puede observar en la insolvencia de la persona natural no comerciante, debe inicialmente acudir a una negociación de deudas ante un conciliador, que cumple funciones meramente administrativas, aparte de una única atribución, la de certificar alguna de las siguientes situaciones; la ocurrencia de aceptación al trámite, fracaso de la negociación, celebración del acuerdo o declaratoria de incumplimiento. En el evento de presentarse controversias entre deudor y acreedores, que se presentan con mucha frecuencia, dentro de la etapa de negociación de deudas en donde el operador es el conciliador, se tendrá que acudir a un juez civil

municipal para que resuelva el asunto objeto del desacuerdo, igual que fracasada la negociación se debe acudir al juez municipal trayendo de nuevo la necesidad de una autoridad judicial que efectivamente garantice los derechos a las partes. Se concluye entonces, que a pesar de hacer ver el procedimiento como ajeno a ser un proceso judicial, en definitiva, lo es. En la Ley 1116, en cambio, se actúa frente al juez en todos los casos, sea este de la jurisdicción ordinaria o de la Superintendencia de Sociedades, según las circunstancias. En la reorganización e igual en la liquidación. Se presenta de nuevo una razón de peso para entender cuán importante es aplicar criterios semejantes, si no iguales para el proceso de la persona natural no comerciante.

- En cuanto a los efectos, de la admisión al proceso de negociación de deudas, establecidos en el artículo 545 del estatuto proceso 1564 de 2012; o de reorganización, señalados en el artículo 20 de la Ley 1116, contemplan las mismas consideraciones en igualdad de términos y consecuencias añadiendo argumentos a las similitudes planteadas que vienen a engrosar lo planteado en esta obra.

Dada la singularidad de elementos presentes en ambos casos, no era necesario elaborar leyes tratándose del tema del no comerciante, con seguridad con un simple proceso de analogía iuris, bastaba para resolver los temas de insolvencia para estos últimos.

Se sustenta la afirmación en la enorme semejanza que existe entre el caso previsto es decir la Ley de insolvencia empresarial y el no previsto como lo es la Ley de insolvencia de persona natural no comerciante; es evidente al dar lectura a dichas leyes que, no existe diferencia radical respecto al propósito de ambas, por tanto, al ser la analogía un instrumento de interpretación jurídica, correspondía por unidad de materia, en una misma ley, disponer la aplicación de los dos regímenes con las particularidades de cada caso, particularidades que en ningún momento, desvirtúan la posibilidad de abordar las dos situaciones jurídicas de insolvencia.

Se pudo evitar entonces la exhaustiva creación de una ley y el desgaste que ello generó, evitando también figuras decorativas o de creación comercial para el incremento patrimonial de las notarías como lo es la figura del notario- conciliador como director de dicha cuestión. Dada la estructura privada de las notarías, su modo de prestar servicios a la comunidad implica una contraprestación onerosa, que impone costos para la persona que se enfrenta a problemas económicos, por ello, se hace constante la crítica a los costos iniciales de una solicitud presentada por el mismo deudor persona natural no comerciante. Esto no fue analizado por capricho, sino con la armonía constitucional y legal de los principios presentes en la norma de normas, tales como: gratuidad de la justicia, acceso a la justicia, doble instancia, y por extensión, el debido proceso.

RECOMENDACIONES

Al final del recorrido por este análisis, enriquecidos en muchos conceptos en su transcurrir, visto que las diferencias en las figuras jurídicas estudiadas comparten una gran cantidad de características comunes, no obstante buscar una finalidad individual dependiendo del sujeto al que se haga referencia en las mismas, que sin embargo no es más que la circunstancia natural que se desprende de pertenecer por igual al género de proceso concursal o de insolvencia.

Por esa, y las otras razones esgrimidas, es muy conveniente que inicialmente los operadores de insolvencia de persona natural no comerciante, tanto en la etapa de negociación de deudas (el conciliador), como en la liquidación patrimonial (el juez civil municipal), se pongan a tono con la dogmática jurídica y reconozcan en ella su semejanza o igualdad genérica y su diferencia específica aplicando los elementos disponibles en la insolvencia empresarial de tal forma que se consiga mayor economía legislativa y más seguridad jurídica.

La aplicación general de este procedimiento debe considerar las bases comunes a todos los procesos concursales, como son los principios del derecho concursal tales como los de oficiosidad, universalidad, fuero de atracción e igualdad. Ello facilita la comprensión y genera la confianza al operador de insolvencia para que ponga en prácticas los elementos comunes que faciliten ese procedimiento.

Ahora bien, si se ahonda en la verdadera importancia de una mejor resolución de los procesos de insolvencia, lo ideal sería que su conocimiento no esté a cargo de las notarías, las cámaras de comercio o los juzgados civiles. El ente idóneo en definitiva es la Superintendencia de Sociedades; con todo lo que puedan errar, tienen una especialidad enfocada hacia ese fin y por lo tanto cuentan con el personal idóneo, las herramientas y experiencia adecuadas a esas necesidades. Las experiencias de procesos adelantados por los organismos mencionados y que se conocen, en su gran mayoría, han resultado frustrantes.

Y como lo describe, en su parte final, el compendio sobre el derecho concursal publicado por la Universidad Javeriana; "...debe propenderse hacia un sistema que permita corregir errores al tiempo que se profundiza la especialidad. Ello generaría menores costos, mayor eficiencia, más idoneidad en las decisiones, en fin, un aparato estatal más preparado y efectivo para afrontar las diversas crisis económicas que se presenten"⁵⁴.

⁵⁴ Cuadros, N., Fonseca, S., Méndez, A., Gomez, M., Jaramillo, M., Giraldo, D., Ramírez, D., Vargas, C. (2003). *Análisis de los procesos concursales y responsabilidad empresarial*. Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS60.pdf>

BIBLIOGRAFÍA

Accounter. (2010) Pago de gastos de administración y situación jurídica de los contratos fiducia en garantía dentro de un proceso de insolvencia – Ley 1116 de 2006. Oficio 220-034801 – 08/Junio Recuperado de <http://www.accounter.co/normatividad/oficios/pago-de-gastos-de-administracion-y-situacion-juridica-de-los-contratos-fiducia-en-garantia-dentro-de-un-proceso-de-insolvencia-ley-1116-de-2006.html>

Cuadros, N., Fonseca, S., Méndez, A., Gomez, M., Jaramillo, M., Giraldo, D., Ramírez, D., Vargas, C. (2003). Análisis de los procesos concursales y responsabilidad empresarial. Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS60.pdf>

Finanzas Personales. (2011, Septiembre 09). ¿Cómo y cuándo declarase insolvente? Recuperado de <http://www.finanzaspersonales.com.co/credito/articulo/como-cuando-declararse-insolvente/38051>

Gutiérrez, E (2012). Insolvencia de la persona natural no comerciante. GYB JURÍDICOS. Recuperado de <https://gybjuridicos.wordpress.com/2012/10/01/insolvencia-de-la-persona-natural-no-comerciante/>

Hernández, Fernández Baptista. “Metodología de la Investigación”. McGraw Hill 1994. Colombia.

Larrea, A. Análisis crítico del concurso de acreedores en el ecuador y reflexiones para su reforma. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ecuador 2013. P. 39

Millan, K. (2014). Crisis del sistema financiero colombiano en los años 90. Presentaciones Prezi. Recuperado De <https://prezi.com/lfljwarseonn/crisis-del-sistema-financiero-colombiano-en-los-anos-90>

Muñoz, J (2013) Una breve descripción del régimen de Insolvencia de ley 1116 de 2006. Recuperado de <https://munozmontoya.com/2013/11/07/una-breve-descripcin-del-rgimen-de-insolvencia-de-la-ley-1116-de-2006/>

Piedrahita, E (2015). Ley de insolvencia de personas naturales no comerciantes: estudio analítico a partir de la ley 1116 de 2006. Diferencias, similitudes y límites. Universidad Católica de Colombia, Bogotá Recuperado de <http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2158/1/TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf>

Rodríguez Espitia, Juan José (2013). Crisis, procedimientos y descargue: Los cimientos del nuevo régimen de insolvencia de persona natural no comerciante. Recuperado de <https://letrujil.files.wordpress.com/2013/09/15juan-jose-rodriguez.pdf>.

Rodríguez Espitia, Juan José. Nuevo Régimen de Insolvencia. Primera Edición. Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A., 2008. 669 páginas.

Rodríguez Ortega, Julio Armando. Metodología de la Investigación Jurídica. Leyer Editores Ltda. Bogotá, 2009.

Rodríguez, J (2013). Crisis, procedimientos y descargue: Los cimientos del nuevo régimen de insolvencia de persona natural no comerciante. Recuperado de <https://letrujil.files.wordpress.com/2013/09/15juan-jose-rodriguez.pdf>

Superintendencia de Sociedades (2017). Introducción al tema de insolvencia. Curso Virtual: En insolvencia para persona natural no comerciante Recuperado de <http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/Introduccion-cursovirtualinsolvencia.pdf>

Vélez Cabrera, Luis Guillermo y otros. Régimen concursal y de insolvencia colombiano. Segunda edición. Imprenta Nacional de Colombia. Bogotá, 2014. 499 páginas.

a. Normatividad:

- Constitución Política de Colombia
- Código Civil Colombiano
- Exposición de Motivos de la Ley 1116 de 2006
- Ley 116 de 2006
- Ley 1380 de 2010
- Ley 1564 de 2012